

Máster Universitario de Acceso a la Abogacía

Abokatutzaren Jarduerarako Unibertsitatea Masterra

Trabajo Fin de Máster

Masterraren amaierako lana

Título La exposición a agentes biológicos y su incidencia en el ámbito laboral. El caso de las Residencias de la Tercera Edad.

Nombre alumno Argiñe Delgado Mardaras

Fecha 1 de diciembre de 2021

Índice

I. Listado de abreviaturas.....	1
II. Introducción.....	2
III. Agentes Biológicos	
1. Definición de agentes biológicos.....	3
2. Clasificación de agentes biológicos.....	3
3. ¿Cómo se transmiten los agentes biológicos y cómo entran en contacto con la persona trabajadora?.....	4
IV. Obligaciones del empresario: normativa de aplicación.....	5
V. Artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes durante el trabajo.....	5
VI. Procedimiento a seguir para la prevención y control de la COVID-19 en los centros residenciales.....	8
VII. Exposición caso: Residencia Jaizkibel	
1. Introducción: explicación del caso.....	10
2. Marco normativo aplicable.....	10
3. Posición de la empresa: normativa y jurisprudencia esgrimida.....	12
4. Protocolos y formaciones en la Residencia Jaizkibel respecto del COVID-19.....	14
5. Protocolo de limpieza en la Residencia.....	15
6. Fallo del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao.....	18
7. Recurso de Suplicación: Formalización e impugnación.	
a) Formalización del Recurso de Suplicación.....	19
b) Impugnación al Recurso de Suplicación.....	21
VIII. Recomendaciones que se proponen al cliente.....	27
IX. Conclusiones finales.....	28

Se adjuntan Anexos

I. Listado de abreviaturas

ATS Auto del Tribunal Supremo.

BOB Boletín Oficial de Bizkaia

CCOO Comisiones Obreras.

ESK Ezker Sindikalaren Konbergentzia/ Convergencia de Izquierda Sindical

ELA Eusko Langileen Alkartasuna/Solidaridad de los Trabajadores Vascos.

EPI(s) Equipo de Protección Individual

EPES Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

LRJS Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

RD Real Decreto.

RSP Reglamento de Servicio de Prevención

STS Sentencia del Tribunal Supremo.

SME Sindicato Médico de Euskadi

STSJPV Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

TS Tribunal Supremo.

TSJ Tribunal Superior de Justicia.

UGT Unión General de Trabajadores.

II. Introducción

Este trabajo aborda la exposición a agentes biológicos y su incidencia en el ámbito laboral con una aproximación al caso de la Residencia de la Tercera Edad, concretamente, la Residencia Jaizkibel.

La protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa, que rebasa del mero cumplimiento de un conjunto predeterminado de obligaciones del empresario. El plan de prevención se desarrolla desde el momento en el que se diseña el proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos de los puestos de trabajo así como su actualización periódica cuando las circunstancias cambien. En efecto, no se puede olvidar la información y formación a las personas trabajadoras con el objetivo de evitar riesgos durante la jornada laboral.

Con esta finalidad, este trabajo va a analizar la circunstancia de la Residencia Jaizkibel. Se aborda desde la perspectiva del sindicato demandante pero, sobre todo desde el punto de vista del empresario en el que las medidas que toma la empresa superan, ampliamente, lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Concretamente, en el caso que se va a proceder a analizar posteriormente, se aplica el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Dicho precepto establece que *“Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo”*, y la jurisprudencia de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo manifiesta que ese precepto es una disposición mínima, como más adelante se explicará. Por consiguiente, las empresas pueden tomar decisiones que amplíen esas medidas para evitar riesgos a las personas trabajadoras. Asimismo cabe preguntarse qué ocurre cuando dichas personas tienen jornada partida.

Por último, para la realización de este trabajo se han tenido en cuenta la preservación de los datos de las personas que forman parte de este proceso conforme lo dispuesto en el Código Deontológico de la Abogacía Española¹, Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española² y Reglamento de Procedimiento Disciplinario aprobado en el Pleno de 27 de febrero de 2009³

¹ Consejo General de la Abogacía Española. (27 de febrero de 2009). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de <https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/05/Codigo-Deontologico-2019.pdf>

² Consejo General de la Abogacía Española. (2019). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4568&p=20210324&tn=2>.

³ Boletín Oficial del Estado. (24 de marzo de 2021). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/reglamento_procedimiento_disciplinario_pdf.pdf

III. Agentes biológicos: Definición, clasificación y transmisión

1. Definición de agentes biológicos.

Los agentes biológicos están definidos en el artículo 2 del Real Decreto, ya citado, como *“microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”*. Por consiguiente, los agentes biológicos son seres microscópicos causantes de los daños a los humanos⁴. Del mismo modo, el Manual de Seguridad y Salud en residencias para la Tercera Edad realizado entre la Mutua FREMAP y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para el año 2021 manifiestan que los riesgos más frecuentes como consecuencia de las exposiciones a agentes biológicos, son las enfermedades infecciosas⁵.

Por lo tanto, una infección es el resultado del establecimiento e interacción de un microorganismo en un organismo que actúa como huésped del mismo⁶.

2. Clasificación de agentes biológicos.

En virtud del artículo 3.1 del Real Decreto 664/1997⁷ los agentes biológicos se clasifican en función del riesgo de infección en cuatro grupos:

- Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
- Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
- Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
- Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad así como sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

⁴ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (s.f.). Recuperado el 10 de septiembre de 2021, de <https://www.insst.es/-/como-se-transmiten-los-agentes-biologicos-y-entran-en-contacto-con-el-trabajador%20->

⁵ FREMAP. (2021). Recuperado el 7 de octubre de 2021, de <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.056%20-%20M.S.S.%20Residencias%20Tercera%20Edad.pdf>

⁶ Óp. Cit. FREMAP. (2021). Recuperado el 7 de octubre de 2021...

⁷ Boletín Oficial del Estado. (24 de julio de 1997). Recuperado el 11 de octubre de 2021, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144>

3. ¿Cómo se transmiten los agentes biológicos y cómo entran en contacto con la persona trabajadora?

Los agentes biológicos se dispersan y se transmiten a través del aire, por bioaerosoles; a través del agua o los alimentos; por contaminación de superficies, herramientas u objetos (fómites) y a través de otros seres vivos (reservorios, hospedadores y/o vectores). Una vez dispersados en el ambiente laboral, la forma mediante la cual el agente biológico penetra al organismo del trabajador y, por la cual resulta un patógeno, se conoce como vía de entrada⁸.

IV. Obligaciones del empresario: normativa de aplicación.

El empresario debe elaborar una evaluación de riesgos laborales en los puestos de trabajo conforme lo dispuesto en el artículo 16.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de ahora en adelante LPRL. En el apartado primero se relata que *“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente”*. Dicho apartado continúa diciendo que el plan de prevención de riesgos laborales *“deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan”*. Y el apartado 2 del mismo precepto manifiesta que los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada que son: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

Además trayendo lo dicho anteriormente, el empresario debe de cumplir con lo dispuesto en el artículo 41.1 del V Convenio Colectivo Sectorial del Centros de la Tercera Edad de Bizkaia⁹ manifiesta que *“El personal tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”*. Además en cumplimiento de su deber de protección la empresa ha de garantizar *“la seguridad y la salud del personal a su servicio frente a los riesgos laborales en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Igualmente, la empresa está obligada a garantizar una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, al igual que cuando se produzcan cambios de actividades, tareas o se introduzca nuevas tecnologías o cambios de puesto de trabajo, al personal. Esta formación se impartirá preferentemente en horario de trabajo”*. Por último, el artículo 4.5 del RD 664/1997 señala que *“si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se*

⁸ Óp. Cit. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (s.f.). Recuperado el 10 de septiembre de 2021,....

⁹ Boletín Oficial de Bizkaia (18 de febrero de 2018). Recuperado el 7 septiembre de 2021 https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/02/09/III-26_cas.pdf?hash=a6729e1317fe8fc165cb8ee8e7bf58ac

aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario”.

El artículo 4 del RD 664/1997 define el marco y el alcance de la evaluación de los riesgos originados por la exposición a agentes biológicos tal y como se contempla en la LPRL y en el RSP. En particular, la evaluación de riesgos tiene como finalidad la obtención de información necesaria para tomar una decisión adecuada, respecto de la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas, así como el tipo de medidas que se han de adoptar (artículo 3.1 RSP)¹⁰. Por lo tanto, la eliminación de los riesgos evitables corresponde realizarla en las fases de concepción y diseño de la actividad laboral, con el fin de evitar las condiciones que permiten el asentamiento, así como favorecer el desarrollo de agentes biológicos y, así, evitar todas las situaciones de riesgos para la salud y seguridad de las personas trabajadoras. El empresario lo primero que debe de hacer es determinar la presencia de agentes biológicos en el lugar de trabajo puesto que puede suponer un riesgo que es necesario proceder a evaluar. La evaluación de riesgos debe determinar la naturaleza, el grado y la duración existentes en el lugar de trabajo y recogidos en el artículo 2 del RD 664/1997. En efecto, el artículo 4.3 RSP manifiesta que *“La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de esta norma”*. El apartado 2 del artículo 2 del RD 664/1997 dispone que *“Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos”*. Además se realizará una nueva evaluación de riesgos cuando se haya detectado que una serie de personas trabajadoras hayan contraído una infección o enfermedad como consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo.

V. Artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes durante el trabajo.

Recordemos lo dispuesto en el artículo 7.2 del RD 664/1997 *“los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo”*.

Las personas trabajadoras que estén implicadas en la atención a los residentes deberán de realizar el lavado de manos tantas veces como la práctica asistencial considere necesario. De la investigación se ha extraído la conclusión a través de los protocolos y de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo que la aplicación de la medida de 10 minutos para el aseo antes de la comida y antes de abandonar el trabajo, carece de sentido. En el sector analizado, es importante señalar que la normativa se ha quedado obsoleta, es decir, la realidad ha superado ampliamente lo expresado en el Real Decreto.

¹⁰ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2014). Recuperado el 6 de septiembre de 2021, de https://www.insst.es/documents/94886/96076/agen_bio.pdf/f2f4067d-d489-4186-b5cd-994abd1505d9

Tanto es así que la jurisprudencia más reciente reconoce que la protección ha ido más allá de lo regulado en la disposición mínima del Real Decreto, ya citado. En concreto, el Auto de la Sala del Tribunal Supremo de fecha 22 de septiembre de 2020¹¹ dispone que *“esta medida se trata de una disposición mínima aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral, situación en la que se encuentran afectados por el conflicto. Añade que la evaluación de riesgos no dice que la medida sea innecesaria sin que pueda prevalecer la oposición del técnico de prevención sobre la disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados”*.

La Sentencia nº 3068/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Málaga de fecha de 14 de abril de 2016 y Sentencia nº 3110/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede en Málaga de fecha 3 de marzo de 2016 disponen que *“en desarrollo del RD 664/1997 se dictó por Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo una Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, que contiene en beneficio de los trabajadores menciones específicas y reglas adicionales de protección en función de las tareas profesionales a realizarse en cada caso particular y agentes vinculados a las mismas, que viene a no sujetarse exactamente a los parámetros de los apartados 2 y 3 del artículo 7, por ello han de entenderse como estándares mínimos de protección que por ende no han necesariamente de ser cumplido exactamente en todo momento, cuando los aplicados mejoran y son eficaces que aquellos”*. Asimismo, la resolución judicial manifiesta que *“consta acreditado por la documental aportada que la demandada tiene establecidas en el hospital específicas medidas de higiene de sus empleados, como el distintivo manos seguras y la higiene de manos tras la atención de cada paciente, por lo que no solamente no limita a los trabajadores de que puedan disponer de 10 minutos de aseo antes de la comida y antes de marcharse, sino que viene a incitar y a fomentar que tal higiene sea llevada a cabo continuamente durante la jornada laboral, cada vez que lo requiera la práctica asistencial, y ello en cumplimiento y seguidamente de los dictados de la Guía Técnica oficial anteriormente indicada”*.

Por último, la Sentencia nº 652/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede en Sevilla de fecha de 2 de febrero de 2007 dispone que *“basándose en lo expuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, el cual efectivamente, expresa, refiriéndose a las actividades en que existía riesgo para la salud o seguridad, de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos que “los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo” y, en principio, esta norma es de indudable aplicación a los demandantes, pero en el presente caso esta medida, que puede considerarse mínima, está ampliamente superada por la actuación empresarial, porque la misma considera necesario, y así lo establece en los protocolos específicos para la prevención de riesgos biológicos y manejo de equipos de protección individual, que el aseo personal*

¹¹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 10 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/688bf90519743aa6/20201016>

se efectúe siempre que se produzca una atención sanitaria, de manera que, cuando se esta situación de disponibilidad, se esté perfectamente aseado y preparado para una nueva actuación, con lo cual se puede dar la circunstancia de que el aseo se produzca varias veces en la jornada de trabajo, aseo que no está sujeto a tiempo límite sino que es necesario para que se esté en condiciones de atender a un nuevo servicio de asistencia sanitaria, y únicamente cuando se concluye esta actividad de aseo, de reposición y de limpieza, es cuando se comunica al centro de coordinación la situación de disponible del equipo de emergencia, por lo que si termina la jornada laboral en situación de disponibilidad, los trabajadores se encuentran perfectamente aseados sin necesidad de volver a asearse, y si coincide el final de la jornada con la atención de pacientes, se sigue prolongando la jornada de trabajo, no hasta que termina la actuación sanitaria, sino hasta que, después de está, se encuentran de nuevo perfectamente aseados y preparado el equipo de emergencia, y por tanto lo dispuesto en el artículo 7.2 se cumple e incluso queda ampliamente superado por el sistema de funcionamiento de EPES y por los mecanismos establecidos de control de riesgos”.

Dicha resolución continua diciendo que “si el personal de la empresa demandada procede de forma sistemática, exhaustiva y protocolizada a su descontaminación y desinfección después de cada servicio sanitario y por el tiempo necesario sin limitación, la aplicación formalista de la exigencia de los diez minutos de aseo personal antes de finalizar la jornada carece indiscutiblemente de lógica alguna, por lo que, al cumplirse perfectamente lo dispuesto en el Real Decreto citado, la demanda debe ser desestimada, máxime que además el artículo 4º, que establece la obligación de proceder a la evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, señala que “si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo, pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5º al 13º de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario”, y hay que tener en cuenta que la evaluación de riesgos señala como nivel de probabilidad del riesgo “bajo” (tres sobre diez), y en cuanto a la ponderación de riesgo, presenta un nivel nueve sobre cien, que equivale a su consideración de “tolerable”, es decir que no se necesita mejorar la acción preventiva, y por tanto sería inaplicable lo dispuesto en los artículos 5º al 13º del Real Decreto, por innecesarios acogándose precisamente a la citada norma, por lo que, como se dijo, la demanda debe ser desestimada”.

En efecto, es importante señalar lo regulado en el artículo 14.1 LPRL “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. La empresa cumple con este precepto en tanto en cuanto al dar a las personas trabajadoras medidas superiores a lo estipulado en el artículo 7.2 del RD 664/1997.

En concreto, la Sentencia nº 1032/2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 2 de mayo de 2017¹² en el que dispone que *“en lo que hace a la medida de los 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y de otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo, estando la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 664/1997 como disposición mínima aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral”*. Tal precepto es un mínimo por lo que queda superada y claramente mejorada por la práctica empresarial, permitiendo a todas las personas trabajadoras afectadas asearse antes de comer o, acabar la jornada laboral, y todas las veces que se estimen oportunas. La medida contemplada en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997 se antoja que pudiera ser una medida innecesaria, por las decisiones que la empresa ha implantado en pro de la seguridad de la plantilla del centro. En definitiva, las medidas tomadas por la empresa son más eficaces que lo regulado en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997.

VI. Procedimiento a seguir para la prevención y control de la COVID-19 en los centros residenciales.

Todo lo expuesto, se ha incrementado ante la aparición de la Covid-19. En particular, las Residencias han establecido un Plan General de Intervención en los protocolos actualizados (Convivencia con Covid) tiene como medidas para escalonar actividades de profesionales (entradas, descansos, uso de oficinas para profesionales, uso de controles...). Del mismo modo, se mantiene la hora de entrada al centro, escalonado el acceso a vestuarios (organización por plantas), de manera que se asegure la estancia de un grupo menor de 5 personas, manteniendo la distancia de seguridad. Asimismo se fichará tanto a la entrada como a la salida del turno de trabajo por medio de una huella dactilar realizando el siguiente procedimiento: Lavado de manos mediante solución hidro-alcohólica (disponible al lado del dispositivo de fichaje); Fichaje; Lavado de manos mediante solución hidro-alcohólica. Igualmente, se realiza un cronograma de descanso por módulos y perfil profesional, de forma escalonada, definiendo las siguientes áreas: la Planta Baja: se realiza el descanso de personal en el office de la propia planta; Planta Primera: se realiza el descanso de personal en el office de la propia planta; Planta Segunda se realiza el descanso de personal en el office de la propia planta; Personal de limpieza en su propia área de descanso, ubicado en la planta -1; Personal de cocina vestuario y área de descanso independientes, fuera del área de habitabilidad, planta -1.

Por otro lado, se realiza la toma de la temperatura de todo el personal en el momento de acceder a planta, así como en el momento de finalización del turno, registrando la medida en papel para el posterior control por Coordinación de Auxiliares y Supervisión de enfermería. A la entrada del centro la empresa ha habilitado un área para la realización de lavado de manos con una solución hidro-alcohólica y colocación de la protección respiratoria (mascarilla

¹² Cendoj. (s.f.). Recuperado el 12 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17ce5a14ef6570d8/20170801>

quirúrgica). A la entrada de cada modulo se deberá colocar un par de guantes y nuevo lavado de manos. A la salida del turno se procederá a la retirada y desechado de guantes (cubo resto), así como lavado de manos con solución hidro-alcohólica, previo acceso a los vestuarios, donde tras la retirada del uniforme para el lavado diario, se retira la mascarilla quirúrgica que se desecha en un cubo.

Por último, se limita el empleo del ascensor a 2 personas, sin embargo, se contemplarán excepciones siempre que sean personas de la misma unidad convivencial acompañados de su auxiliar de referencia, con uso de mascarilla quirúrgica. Tras todo lo expuesto se ha de prestar especial consideración tanto a la colocación como retirada de los Equipos de Protección Individual de ahora en adelante EPI ¹³.

En primer lugar, la colocación del EPI; para ello es importante identificar todas las amenazas y riesgos, para seleccionar el equipo de protección más adecuado. La planificación debe hacerse con la debida antelación respecto de la puesta y retirada así como verificar si se dispone de la ayuda de otro profesional, un espejo y contenedores o materiales adecuados para desechar el equipo cuando se retire el EPI. Posteriormente, la plantilla se pondrá otra bata de protección contra la salpicadura de fluidos biológicos o secreciones. Tras la correcta colocación será el momento de ponerse la protección respiratoria y ocular. Para ello, la plantilla dispone de dos opciones; 1) Usar una pantalla facial de protección frente a salpicaduras y 2) Combinar el uso de mascarilla filtrante y gafas de protección. En especial, es importante manifestar que este equipamiento deberá de ser una protección de nivel alto (mascarillas auto-filtrantes contra partículas FFP3 o media máscara provista con filtro contra partículas P3) si se realizan procedimientos que puedan generar aerosoles, como en tratamientos respiratorios, aspiración de secreciones, intubación, reanimación cardiopulmonar entre otros. Por último, las personas trabajadoras se colocaran los guantes, teniendo en cuenta que cubran y queden por encima de los puños de la bata.

En segundo lugar, una vez concluida la atención sanitaria así como en el momento de retirar el EPI; las personas trabajadoras deberán de hacerlo con la finalidad de evitar la contaminación; la suya propia, la de otras personas o su entorno. Por ello, lo primero se retirará aquellos materiales más contaminantes. La plantilla se quitará en primer lugar la bata y los guantes, de forma conjunta. Para ello, la bata se retirará enrollándola hacia delante y cuando lleguemos al final sacaremos los guantes. Posteriormente, las personas trabajadoras procederán a realizar la higiene de manos, para la cual podemos utilizar solución hidro-alcohólica. Tras esto, la plantilla se retirarán los equipos de protección respiratorios y oculares. En el caso de haber usado una pantalla facial, las personas trabajadoras las retirarán de forma segura, de atrás a adelante. Y si usan gafas y mascarilla filtrante, eliminarán, en primer lugar, las gafas de atrás a adelante, y después la mascarilla, también de atrás hacia delante. Una vez que se hayan retirado los EPIs se realizara de nuevo el lavado de manos.

¹³ José, A. d. (26 de octubre de 2020). *Coronapedia*. Recuperado el 7 de octubre de 2021, de <https://www.coronapedia.org/base-conocimiento/colocacion-y-retirada-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-frente-a-covid-19/>

Por último, a medida que se vayan retirando los EPIs desechables se tendrán que depositar en contenedores de desecho adecuados así como deberán de ser tratados como residuos biosanitarios. Se adjunta como Anexo 1 las imágenes de cómo han de proceder para su colocación y retirada.

VII. Exposición del caso: Residencia Jaizkibel

1. Introducción: explicación del caso.

En este asunto se solicita el reconocimiento de un derecho colectivo a las personas trabajadoras de la Residencia Jaizkibel. La parte demandante solicita en su escrito el derecho de disponer de 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el centro de trabajo conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 del RD 664/1997. Concretamente, el presente conflicto colectivo afecta a las personas trabajadoras de la Residencia Jaizkibel ubicadas en las siguientes categorías profesionales:

- Enfermería
- Fisioterapeuta
- Médicos
- Gerocultor
- Trabajador social
- Personal de mantenimiento
- Psicología

2. Marco normativo aplicable

Este procedimiento se incoa por la Confederación Sindical ELA frente a Residencia Jaizkibel, ESK y Unión General de Trabajadores. El 14 de abril de 2021 se realizó la conciliación, cumpliendo así, lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Jurisdicción Social ante el Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao. No obstante, la conciliación finaliza sin alcanzar un acuerdo entre las partes.

Recordemos las normas en liza los artículos 4.5, 4.6 y 7.2 del Real Decreto 664/1997.

Sin embargo, la medida regulada en el artículo 4.5 del mismo cuerpo legal se aplicará salvo que los resultados de la evaluación de riesgos fuesen innecesarios. En el apartado 6 del mismo precepto en relación con lo recogido en el Anexo 1, pues en ambos, están contemplados que las personas trabajadoras de asistencia sanitaria se les aplicaran las medidas reguladas en los artículos 5 a 13 del Real Decreto sin distinguir entre actividad sanitaria pública y privada. Concretamente, dicho precepto dispone que *“El Anexo 1 de este Real Decreto contiene una lista indicativa de actividades en las que podría resultar de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior”*. Por lo tanto, tras enunciar el Anexo 1, se ha de manifestar concretamente el punto 4 del RD 664/1997 el cual dispone que *“los trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y anatomía y patológica”*. En concreto, la Residencia Jaizkibel, analizado posteriormente, desarrolla una actividad socio-sanitaria de carácter privado.

La Disposición Final Primera del RD 664/1997 dispone que *“El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en*

el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo". Por consiguiente, la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo no es vinculante pero se puede hacer uso de él a modo de guía.

En dicha Guía Técnica dispone, en su texto literal, que *"así, en el ámbito sanitario, y para los trabajadores directamente implicados, en atención a los pacientes o en el laboratorio, el lavado de manos debe de ser tan frecuente como requiera la practica asistencial. En este caso, la estricta aplicación para el aseo antes de la comida y al abandonar el trabajo no tendría sentido"*¹⁴. Por consiguiente, cuando la higiene de manos se realice de forma frecuente, no tiene sentido la aplicación de los 10 minutos para el aseo antes de la comida y al abandonar el puesto de trabajo.

Por otra parte, se ha de señalar el Manual de Seguridad y Salud en Residencias para la Tercera Edad realizado entre la Mutua FREMAP¹⁵ y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el año 2021, contempla una serie de normas de higiene personal que se recogen a continuación¹⁶:

- Protégete las heridas y lesiones de las manos con un apósito impermeable, antes de iniciar la actividad laboral.
- Lávate las manos al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, fluidos corporales o partes íntimas de las personas.
- Tras el lavado de las manos y siempre que sea posible, sécatelas con toallas de papel desechables o corriente de aire.
- No comas ni bebas en el área de trabajo.

3. Posición de la empresa: normativa y jurisprudencia esgrimida.

Recordamos que la parte contraria ha interpuesto una demanda colectiva para el reconocimiento del derecho colectivo de las personas trabajadoras a disponer de 10 minutos para el aseo personal antes de comer y otros 10 minutos antes de abandonar el centro de trabajo conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 del RD 664/1997. Por consiguiente, se ha de manifestar que a este supuesto se aplican las siguientes disposiciones:

- ✓ El artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997 se establece una serie de disposiciones mínimas que se aplican a las actividades en las que las

¹⁴ Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Página 31 Madrid 2014. Obtenido de https://www.insst.es/documents/94886/96076/agen_bio.pdf/f2f4067d-d489-4186-b5cd-994abd1505d9

¹⁵ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

¹⁶ Manual de Seguridad y Salud en residencias para la Tercera Edad realizado entre la Mutua FREMAP y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para el año 2021 en su página 29 y siguientes de <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.056%20-%20M.S.S.%20Residencias%20Tercera%20Edad.pdf>

personas trabajadoras están o pueden estar afectados a agentes biológicos.

- ✓ Conforme lo dispuesto en el artículo 4.5 del Real Decreto 664/1997 literalmente manifiesta que *“Si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario”*.

Por lo tanto, el Real Decreto que se aplica en este caso, está compuesto de una serie de disposiciones mínimas que han de ser aplicadas por el empresario. Entre todas esas disposiciones, es importante señalar el artículo 7.2 que en su literal dispone que *“Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo”*. Sin embargo, esa medida es innecesaria cuando los resultados de las evaluaciones de riesgos consideren que es innecesario. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifiestan que es necesario el aseo a lo largo de la jornada laboral en todas las residencias de la Tercera Edad y, por lo tanto, no tiene sentido establecer los 20 minutos solicitados por la parte actora. Tanto es así que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha manifestado respecto de la medida solicitada por el demandante en varias sentencias. En primer lugar, en la Sentencia nº1649/2020 de la Sala de lo Social de fecha 15 de diciembre 2020¹⁷ dispone que la demanda se desestima aunque de la evaluación de riesgos no se recoge que la medida, que la parte actora solicita, sea innecesaria.

En segundo lugar, la Sentencia nº 592/2021 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 23 de marzo de 2021 (Residencia Aita Menni) por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Bilbao de fecha 17 de julio de 2020¹⁸. La sentencia desestima la demanda de conflicto colectivo promovida por los sindicatos ELA y ESK en contra de la Residencia Aita Menni, por cuanto las medidas preventivas y protocolos de actuación vigente en la empresa, no es necesaria la adopción de las medidas contempladas en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997.

En cuanto a las evaluaciones de riesgos se desprenden que las medidas adoptadas por la empresa amplían las medidas reguladas en el Real Decreto 664/1997. Por lo tanto, dichas medidas permiten a las personas trabajadoras asearse, continuamente, durante la jornada de trabajo. Aparte de las evaluaciones de riesgos han de tenerse en cuenta todos los protocolos de higiene que la empresa ha adoptado y la formación impartida a la plantilla. Concretamente, las evaluaciones de riesgos se recogen de forma resumida en el Anexo 2. Por consiguiente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en

¹⁷ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 14 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/daa1b6097c0bc5bf/20210329>

¹⁸ Cendoj. (s.f.). Recuperado el septiembre 15 de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e42cb7425ffe064d/20210528>

la Sentencia de Osakidetza¹⁹ tiene como requisito que en la evaluación de riesgos conste expresamente que las medidas no son necesarias y la parte actora, también reconoce en el Hecho Séptimo de su escrito de demanda *“Que se ha llevado a cabo en la empresa una Evaluación específica de Riesgos Laborales en la que se contempla el riesgo por exposición a agentes biológicos, y en definitiva se viene concluir que la aplicación de la medida establecida en el apartado 2º del artículo 7 del RD 664/1997 no resulta necesaria en el centro de trabajo a la vista de las medidas higiénicas y de protección adoptadas en cada uno de los puestos de trabajo en los que se ha evaluado el riesgo biológico”.*

Asimismo se han adoptado los protocolos de higiene de manos, cursos de formación impartidos, puesta a disposición de EPIs, etc., sin perjuicio de que la evaluación de riesgos se exprese que es innecesaria la aplicación de la medida regulada en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997. Posteriormente, se van a enumerar todos los protocolos que existen en la empresa, en los cuales están recogidas todas las medidas adoptadas para fomentar el aseo durante la jornada laboral. Por lo tanto, la medida de higiene de manos de 10 minutos antes de comer y 10 minutos antes de abandonar el centro de trabajo ha quedado superada con las medidas que adopta la empresa. Exactamente, la empresa ha tomado todas las medidas necesarias por medio de protocolos, recordatorios de dichos protocolos, cursos de formación, entre otros. La mercantil ha adoptado todas las medidas que ha considerado necesarias con la aprobación de los siguientes protocolos todos ellos anteriores al COVID 19 y se encuentran explicados en el Anexo 3:

- Higiene de manos del año 2018.
- Protocolo de aislamiento del año 2017.
- Protocolo de prevención y tratamiento de infecciones del año 2013.
- Protocolo SARM del año 2016.
- Protocolo de la Gripe del año 2016.
- Riesgos generales, medidas preventivas y protección.
- Protocolo abordaje de síntomas.

Todos estos protocolos son puestos a disposición de la plantilla dentro del manual de bienvenida y normas básicas de funcionamiento. Dicho documento incluye el manual de bienvenida, las normas de funcionamiento interno, la carta de derechos y deberes de usuarios y trabajadores, el documento de compromiso con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y documentación relativa a la evaluación de riesgos laborales. La documentación de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto, comprende la comunicación de la modalidad de la organización preventiva, riesgos asociados a su puesto de trabajo y acciones preventivas, la política de Prevención de Riesgos Laborales, funciones y responsabilidades de prevención, reglas generales ante una emergencia y, por último, instrucciones de uso y compromiso de utilización de EPIs. De igual forma, la plantilla tiene el conocimiento de todas las medidas implementadas en la empresa tales como continuos recordatorios de la higiene de manos o el uso correcto de EPIs.

¹⁹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/daa1b6097c0bc5bf/20210329>

Tal es así que la plantilla dispone de recordatorios en los ascensores de la residencia o el comunicado emitido por el Médico especialista en geriatría en fecha de 21 de marzo de 2017, por medio del cual se comunica a la plantilla la disponibilidad de EPIs así como la obligación de seguir las medidas universales de higiene, como son el lavado de manos y el uso de guantes. A saber, en el comunicado se recuerda a la plantilla *“...que siempre deben de seguirse medidas universales que garanticen evitar el riesgos de transmisión entre pacientes y trabajadores del centro (lavado de manos, uso de guantes etc.). Para facilitar el cumplimiento de estas medidas, se dota al Centro de varios puestos de dispensación de gel hidro-alcohólico”*.

4. Protocolos y formaciones en la Residencia Jaizkibel respecto del COVID 19.

La Residencia posee protocolos generales, y teniendo en cuenta la situación actual, se han de manifestar protocolos relativos a la Covid-19 que se han aprobado y comunicado desde el principio de la pandemia:

- **Plan General de intervención de la Residencia** en el que se desarrolla la necesidad de realizar el lavado de manos mediante solución hidro-alcohólica al fichar a la salida y a la entrada del centro de trabajo.
- **Área aislamiento Jaizkibel SARS COV-2019** en el que se desarrolla todos los pasos para colocar los EPIs, siendo el primero de ellos el lavado de manos antes de colocarse la bata o el buzo impermeable.

Por otro lado, la Empresa ha realizado una actualización de todas las evaluaciones de riesgos incluyendo, concretamente, todos los riesgos provocados por la exposición al SARS COV-2.

En efecto, en esas actualizaciones establecen medidas preventivas en la que la higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección: la higiene de manos se hará de manera general con agua y jabón. Además, deberá realizarse según la técnica correcta.

Por último, los protocolos y cursos de formación existentes e impartidos en la empresa, han sido tratados en el Comité de Seguridad y Salud de la Empresa. Es importante manifestar que los Representantes de los Trabajadores tienen conocimiento de todas las medidas preventivas que se han comunicado a la plantilla durante estos años y, por ello, tiene en su conocimiento, un resumen de todas las Actas del Comité de Seguridad y Salud desde 2017 hasta enero de 2021.

5. Protocolo de limpieza en la Residencia Jaizkibel

La empresa tiene contratado un servicio de limpieza llamado Kalamua el cual realiza la limpieza y, desinfección, de los uniformes de trabajo de todas ellas a diario. Además, los uniformes son nominativos, esto es, incluyen el nombre, apellidos y cargo de cada una de ellas. Por consiguiente, la plantilla siempre presta servicios con el uniforme limpio. Del mismo modo, en la zona de

vestuarios se sitúan unos “burros” con todos los uniformes limpios por lo que cada persona trabajadora al llegar al centro, tiene que coger su uniforme perfectamente limpio. Cuando finaliza la jornada, al lado de las duchas habilitadas para que la plantilla pueda asearse al finalizarla, están situados unos contenedores verdes en los que cada persona, deberá depositar el uniforme empleado.

Por lo expuesto, las medidas que adopta la empresa superan las previstas en el Real Decreto 664/1997, puesto que son más eficaces que las disposiciones mínimas reguladas en dicho texto. Del mismo modo, debería de alcanzarse una conclusión similar tal y como ha sucedido en Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco:

• **Sentencia de la Residencia AITA MENNI: Sentencia nº 592/2021 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 23 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao en fecha 17 de julio de 2020²⁰.** Por lo tanto, el Tribunal valoró positivamente los siguientes aspectos:

- La existencia de protocolos en la empresa en los que se determine los diferentes casos en los que se exige el aseo.
- Los protocolos que existen en la empresa aseguran la higiene de manos antes de comer y finalizar la jornada laboral, y en muchas otras ocasiones no reguladas en las normas mínimas del RD 664/1997.
- La existencia en la empresa de un protocolo concreto frente al SARM.

En la Residencia Jaizkibel se dan estos tres aspectos por lo que no cabe imponer la pretensión de la parte actora.

• **Sentencia de OSAKIDETZA: Sentencia nº 1649/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 15 de diciembre de 2020 se desestima la demanda interpuesta por ELA, SATSE, LAB, CCOO, UGT y ESK frente Osakidetza²¹.** Tiene como fundamento la desestimación de la demanda aunque la evaluación de riesgos no recoge específicamente la medida reclamada, sea innecesaria. La resolución presenta las siguientes conclusiones:

- El Fundamento Jurídico Primero dispone que *“el Tribunal considera conveniente comenzar sus razonamientos poniendo de relieve que en la actual situación de crisis sanitaria las condiciones del ambiente laboral son profundamente diferentes en uno y otro caso”*.
- *“Los trabajadores de las residencias de la tercera edad están en contacto habitual con fluidos corporales que requieren higiene frecuente. Pero no tiene contacto con agentes biológicos, salvo casos excepcionales de*

²⁰ Cendoj. (s.f.). Recuperado el septiembre 15 de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e42cb7425ffe064d/20210528>

²¹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/daa1b6097c0bc5bf/20210329>

personas que padezcan enfermedades infecciosas o contagiosas". Es importante señalar que no se puede equiparar a los trabajadores de las residencias con el personal sanitario.

- Se materializa diversos aseos a lo largo de la jornada, de esa forma, el aseo previo a la comida o el aseo al concluir la jornada, no son distintos ni merecen una dedicación especial.
- Los 10 minutos regulados en el artículo 7.2 RD 664/1997, únicamente, tiene fundamento cuando no es procedente, conveniente, posible o práctico hacer paradas a lo largo de la jornada.
- La pretensión no es lógica ni jurídica puesto que la estimación de tal pretensión lleva al absurdo de que cada vez que el personal sanitario toca algo o a alguien, a continuación requiere los 10 minutos de aseo lo cual implicaría varias horas a lo largo de la jornada. Por lo tanto, implicaría una situación *"clamorosamente insostenible"*.

En conclusión, se ha de aplicar la salvedad regulada en el artículo 4.5 del RD 664/1997 puesto que la evaluación de riesgos lo prevé y, además, dispone la Sentencia de Osakidetza que llevaría al absurdo de que cada vez que el personal de la residencia, toca algo o alguien necesita después 10 minutos de aseo. Por consiguiente, implicaría varias horas a este menester y, en palabras del Tribunal, sería una situación clamorosamente insostenible.

Sin embargo, cabe preguntarse qué distinción se hace entre las personas trabajadoras con jornada partida respecto de aquellas que realizan su jornada de forma continua. Para ello, se ha de mencionar la Sentencia del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao en fecha de 13 de febrero de 2019 la cual fue confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 16 de julio de 2019²². Ambas resoluciones disponen que la pausa regulada en el artículo 7.2 del RD 664/1997 no puede extenderse al tiempo de descanso del que disfrutaban las personas trabajadoras con jornada continuada. Por lo tanto, la interrupción de la jornada para comer, se extendería a la plantilla con jornada partida.

La Sentencia de instancia dispone en su texto literal que *"ese tiempo para el aseo personal previo a la comida del artículo 7.2 RD 694/1997, se circunscribe estrictamente a la interrupción de jornada para ese menester, y no se extiende a otras interrupciones de jornada, singularmente al tiempo de descanso del que gozan el personal con jornada continuada conforme al Convenio Colectivo, cualquiera que sea el destino de ese tiempo"*.

En definitiva, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia manifiesta que *"ni el artículo 19 del Convenio Colectivo cuando regula el tiempo de descanso para el personal con jornada continua está pensado para la ingesta de alimento o la toma de café, u otro destino específico que no sea la interrupción de la jornada laboral, ni el artículo 7.2 RD 694/1997, cuando regula los 10 minutos para el aseo personal contempla otros supuestos que no sean la comida en su sentido literal o el abandono del trabajo por fin de la jornada"*. Por lo tanto, *"ni legal, ni convencionalmente, se considera esa pausa de 20 minutos un parón para comer, por lo que no se puede aplicar el artículo 7.2 RD 694/1997"*.

²² Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f2132013ef08ecd0/20191014>

Por último, es importante prestar atención a la Sentencia nº 1649/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de diciembre de 2020, la dictada dentro de un conflicto colectivo promovido frente a Osakidetza²³. El Tribunal reconoce el derecho a los 10 minutos de descanso para el aseo a las personas trabajadoras de las residencias de la tercera edad así como *“el reconocimiento del derecho a que se computara como jornada de trabajo, 10 minutos antes de la comida si la jornada era partida y en todo caso 10 minutos al finalizar la jornada, con el fin de dedicar dicho tiempo al aseo”*.

Por otro lado, es importante señalar que es innecesaria la medida regulada en el artículo 7.2 del RD 664/1997 puesto que así está recogido en la evaluación de riesgos por ser dichas medidas más eficaces y mejores para evitar riesgos a las personas trabajadoras.

Igualmente, se ha de prestar especial consideración lo dispuesto en la Sentencia nº592/2021 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Residencia Aita Menni)²⁴ en la que dispone que teniendo en cuenta las medidas preventivas y los protocolos de actuación vigentes ha de ser de aplicación la excepción regulada en el artículo 4.5 del RD 664/1997. Por consiguiente, las medidas contempladas en el artículo 7.2 del RD 664/1997 son innecesarias.

Como colofón, la Sentencia nº 1649/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de diciembre de 2020 (Osakidetza) dispone que sólo tiene fundamento *“cuando no es procedente, conveniente, posible o práctico hacer aseos intermitentes a lo largo de la jornada, lo que conduce a la necesidad de una limpieza profunda que requiere 10 minutos de dedicación”*. Sin embargo, en este supuesto no se da tal circunstancia en tanto en cuanto las personas trabajadoras de la Residencia Jaizkibel realizan, tal y como se ha señalado en líneas precedentes, las medidas que la empresa adopta.

Del mismo modo, dicha resolución manifiesta que la estimación de la demanda da a lugar a un absurdo cada vez que el personal sanitario *“toca algo o a alguien que de seguido requiera el oportuno aseo, a éste siempre habría que dedicarle siempre 10 minutos, lo que implica sin exageración ni riesgos de equivocarse, que el tiempo dedicado al aseo a lo largo de la jornada sumaría varias horas”*. Por lo tanto, la estimación de la pretensión de la parte actora conformaría una situación clamorosamente insostenible, jurídicamente, en palabras del Tribunal.

6. Fallo del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao.

La Sentencia nº 251/2021 del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao de fecha 9 de junio de 2021 ha desestimado la pretensión interpuesta por la Confederación Sindical ELA en tanto cuanto hace uso de la Sentencia nº 592/2021 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 23 de marzo de 2021 (Residencia Aita Menni). Dicha resolución judicial dispone que se acredita a través de la evaluación de riesgos laborales practicada y vigente

²³ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/daa1b6097c0bc5bf/20210329>

²⁴ Cendoj. (s.f.). Recuperado el septiembre 15 de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e42cb7425ffe064d/20210528>

“que en el ámbito laboral de la demandada la exposición a agentes biológicos es accidental. A ello se une la previsión de la evaluación de riesgos sobre la pormenorizada enumeración de todos los actos que a lo largo de la jornada requieren la inmediata limpieza del trabajador. La escasa exposición a los agentes biológicos y el protocolo de higiene que resulta más estricto y protector que la exigencia legal, implica que el derecho reclamado, previsto por el artículo 7 del Real Decreto 664/1997 cuente con la excepción del art. 4.5 de la misma norma”.

Asimismo, no hay que considerar los 10 minutos a los que se refiere el artículo 7.2 del RD 664/1997 *“tengan como objeto un aseo genérico (no necesariamente orientado a contener el riesgo) tras la realización de las tareas ordinarias, toda vez que la norma en la que estaría incluida esa previsión está relacionada con la materia preventiva, por lo que no puede limitarse al reconocimiento de un derecho genérico. Abunda sobre esta línea de razonamiento el hecho de que el propio precepto quede excepcionado cuando la estrategia de prevención de riesgos adoptada lo haga innecesario, factor este que avala la necesidad de conectar el aseo a que se refiere el artículo 7.2 RD 664/1997 con la contención de un eventual peligro”.*

7. Recurso de Suplicación: Formalización e impugnación.

a) Formalización del Recurso de Suplicación

La parte demandante no está de acuerdo con el fallo de la resolución por lo que formaliza el Recurso de Suplicación frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6. En su escrito de formalización del Recurso de Suplicación toma como fundamento el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales o periciales practicadas²⁵.

Por ello, se solicita la eliminación del párrafo segundo del hecho probado segundo de la sentencia que en su literal dispone que *“el aseo personal necesario, específico y obligatorio es el lavado higiénico de manos, ya que es el único de manifiesta eficacia en la actividad del Centro Jaizkibel”.*

Del mismo modo, no se especifica en qué documento basa su argumento para llegar a esa conclusión. La actora considera que se tiene que añadir un hecho nuevo y, parece ser, el juez no tuvo consideración de lo manifestado por los testigos que declararon en el acto del juicio. Estos testigos señalaron que los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo, dejando la planta, una vez que finalizan su jornada laboral, no cumpliéndose los 10 minutos de aseo de manos regulados en el RD 664/1997.

Asimismo se ha de manifestar que se solicita la adicción de otro hecho en tanto cuanto las personas trabajadoras no disponen de un lugar concreto para la realización del descanso diario, por lo que lo suelen realizar en el office o en los vestuarios. Adicionalmente, según la actora la empresa no garantiza el aseo

²⁵ Boletín Oficial del Estado. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936>

o limpieza de manos de 10 minutos, tal y como establece el RD 664/1997 así como la evaluación de riesgos.

De otro lado, es importante señalar que la parte actora solicita otro motivo, basado en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Seguridad Social para examinar las infracciones de las normas sustantivas o de la jurisprudencia. Especialmente, se vulneran los artículos 4 y 7 del RD 664/1997 y la jurisprudencia relacionada con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 1032/2017 de 2 de mayo, nº 1767/2018 de 25 septiembre²⁶, nº 2240/2018 de 13 de noviembre²⁷, nº 475/2019 de 26 de febrero de 2019²⁸, nº 856/2019 de 7 de mayo de 2019²⁹ y nº1092/2019 de 4 de junio de 2019³⁰.

Dichas sentencias y las evaluaciones de riesgos de la demandada dentro de cada puesto de trabajo, disponen que las personas trabajadoras afectadas están expuestos a riesgos biológicos por contacto con fluidos corporales, piel o mucosas en la atención a los residentes durante la jornada de trabajo. El hecho probado tercero de la sentencia reconoce que en la Evaluación de Riesgos Laborales de la parte demandada, entre otras cosas, se recoge “*Seguir recomendaciones del RD 667/1997, sobre protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos*”. Sin embargo, la evaluación de riesgos, únicamente, está establecido el lavado higiénico de manos, cuando se considere necesario durante la jornada de trabajo y en las 5 ocasiones especificadas por la parte demandada.

En consecuencia, el aseo no se realiza en el sentido más amplio que la empresa ha de respetar y, exigir a las personas trabajadoras, después de la exposición a los riesgos biológicos. En la Evaluación de Riesgos, únicamente, se prevé el lavado higiénico de manos, y cuando sea necesario, así como en las 5 ocasiones concretas por lo que no se realiza el aseo, que la empresa ha de respetar y exigir a las personas trabajadoras después de exponerse a los agentes biológicos. El aseo personal no es una decisión que pueda quedar al arbitrio de la persona trabajadora o del propio empresario, sino que es una medida mínima y universal que ambos han de cumplir. En el escrito de la parte recurrente, la empresa tiene que realizar la limpieza de manos en 5 ocasiones, sin embargo, no hay garantía de que esa limpieza se realice de forma efectiva. Asimismo no garantiza la limpieza de manos y el aseo personal antes de abandonar los puestos de trabajo para el descanso del bocadillo, tampoco cuando las trabajadoras se trasladan a casa una vez concluida la jornada de trabajo.

Por otro lado, los testigos que declararon en el acto del juicio manifestaron que las personas trabajadoras abandonan sus puestos de trabajo,

²⁶ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/50cd0798e1779899/20190304>

²⁷ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/043a161cf1f53a99/20190221>

²⁸ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a14c8ac20d1a051f/20190529>

²⁹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f4ec87c982ce3dac/20190726>

³⁰ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68a8e4ea66f37a8a/20190828>

una vez llegada la hora de finalización del turno y, por lo tanto, no se aplican los 10 minutos antes, para que puedan llevar a cabo el aseo personal que exige el Real Decreto ya citado. La parte recurrente manifiesta que la testigo propuesta corrobora que las trabajadoras tenían 5 ocasiones distintas para limpiarse las manos.

Con todo, la Sentencia recurrida se apoya en la sentencia nº 592/2021 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Residencia Aita Menni)³¹, ya mencionada con anterioridad, manifiesta que las medidas preventivas y protocolos de actuación vigentes en la empresa, hacen innecesaria la adopción de medidas reguladas en el artículo 7.2 del RD 664/1997. Todos los protocolos existentes en la empresa aseguran el lavado de manos antes de comer y de finalizar la jornada de trabajo. Sin embargo, en este caso no se recoge, es más, se regula y se determina que hay que cumplir lo determinado en el RD; *“seguir recomendaciones del RD 664/1997, sobre protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos”*.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado numerosas sentencias que han estimado las pretensiones que defiende la parte actora en estas actuaciones. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 25 de septiembre de 2018 que remite a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de mayo de 2017, sentencia del 13 de noviembre de 2018, sentencia nº 475/2019, de 26 de febrero y sentencia nº 856/2019 de 7 de mayo de 2019. Se adjuntan como Anexo 4 los extractos de las resoluciones.

Como corolario, la empresa establece en la Evaluación de Riesgos el lavado higiénico de manos, por lo tanto, la empresa da valor a ese acto. Además los 2 aseos personales están establecidos en la normativa mínima por ser momentos importantes dado que las personas trabajadoras abandonan sus puestos de trabajo y tienen contacto con el exterior y, por ende, hay más riesgo de contacto.

b) Impugnación al Recurso de Suplicación

A la parte demandada, ahora recurrida, se le notifica el 10 de septiembre de 2021 la Diligencia de Ordenación en la que se notifica la formalización del Recurso de Suplicación, por la parte recurrente en contra de la Sentencia nº 251/2021 del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao de fecha de 9 de junio de 2021; en la que se desestima la pretensión de la parte actora. El Recurso de Suplicación que la parte recurrente presenta, está consta de los 4 motivos. Los tres primeros en relación a la revisión de los hechos y, el último de ellos, relacionado con el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia (artículo 193.c) LRJS)³².

En primer lugar, la parte recurrida dispone que el Recurso de Suplicación no está configurado como una segunda instancia, permitiendo efectuar una nueva revisión de las pruebas documentales y periciales practicadas ajustadas

³¹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el septiembre 15 de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e42cb7425ffe064d/20210528>

³² Óp. Cit. Boletín Oficial del Estado. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021,...

a los intereses de la parte recurrente. Sin embargo, la doctrina mayoritaria³³ manifiesta que *“El legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, y ha construido el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de enero). Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados. De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:*

a) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b) Que el error sea evidente;

c) Que los errores denunciados tengan trascendencia en el Fallo, de modo que, si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.”.

No obstante, la jurisprudencia asimismo dispone que *“En cuanto a la prueba que puede servir de base para la modificación o adición de un hecho probado, sólo puede ser pericial o documental”.* Algo que no ocurre en este caso. Por lo tanto, no vale un documento cualquiera sino que ha de ser concluyente, es decir, que tenga un poder de convicción o decisivo valor probatorio. Por añadidura debe de gozar de una fuerza suficiente para poner de manifiesto el error, por parte del juez de instancia en su resolución. Por otra parte, se ha de manifestar que no procede la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas al albur de lo regulado en el artículo 193 b) del Ley Reguladora de la Jurisdicción Social³⁴. En particular, la parte recurrente solicita la modificación del Hecho probado segundo, destinado a la eliminación del párrafo segundo *“el aseo personal necesario, específico y obligatorio es el lavado higiénico de manos ya*

³³ STSJVP nº 962/2015 de 19 de mayo remite a la STC nº 3/1983, de 25 de enero, STC nº 69/1987 de 14 de abril, STSJ Cataluña nº 8999/1999 de 14 de abril, STSJ Cataluña nº 8340/1999 de 19 de noviembre, STSJVP nº rec. 1391/2000 de 5 de septiembre de 2000.

³⁴ Óp. Cit. *Boletín Oficial del Estado*. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021,...

que es el único de manifiesta eficacia en la actividad del centro Jaizkibel". Tal eliminación es como consecuencia de que en la evaluación de riesgos de cada categoría se reconoce dentro *"de las medidas preventivas seguir recomendaciones del RD 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos"*.

La documentación presentada por la parte demandada, ahora recurrida, que aportó al procedimiento, las evaluaciones de riesgos de todas las categorías de puestos de trabajo de la residencia que deber seguir así como todo lo dispuesto en el RD 664/1997 pone de manifiesto lo que sigue a continuación:

- Aplicar normas de higiene personal antes y después de la atención a cada residente, aunque se empleen guantes, utilizando agua y jabón líquido o soluciones hidro-alcohólicas disponibles en baños comunes y zonas de control, con las indicaciones de uso y modo de lavado de manos.
- Se recomienda la aplicación del tiempo necesario para su higiene personal en función de la tarea realizada y del agente biológico quedando regulado en el procedimiento interno de la empresa.
- Lavarse las manos, entre otras, tras quitarse los guantes, al comenzar y al finalizar la jornada laboral.
- Limpieza personal antes de ingerir alimentos, bebida o tabaco así como evitar la aplicación de cosméticos en el lugar de trabajo.
- Disponen de desinfectantes oculares y cutáneos en el lugar de trabajo.

En las evaluaciones de riesgos manifiestan que se debe de cumplir todo lo establecido en el RD 664/1997, puesto que es un imperativo legal así como un hecho cierto e incontrovertido para ambas partes.

En definitiva, en dichas evaluaciones no se establecen que se debe cumplir con los 10 minutos, sino que lo que establece es el tiempo necesario en función de la tarea realizada y el agente biológico. Todo ello se encuentra regulado en el procedimiento interno de la empresa, ya explicado en líneas precedentes. La empresa, aportó las evaluaciones de riesgos de cada puesto de trabajo y los 8 protocolos en materia preventiva. Por lo tanto, tienen como función ampliar las obligaciones y recomendaciones reguladas en el RD 664/1997. La empresa para hacer valer su pretensión emplea una serie de documentos que se adjunta como Anexo 2 y 3.

Por otra parte, la empresa se opone a lo manifestado por la parte recurrente en tanto en cuanto no procede revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales, y periciales, practicadas conforme lo dispuesto en el artículo 193 b) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social³⁵. La parte recurrente solicita la adición de un nuevo hecho a la sentencia de instancia, tal como *"que los trabajadores de la residencia abandonan sus puestos de trabajo una vez finaliza su jornada laboral, realizando su aseo personal, en su caso, fuera de la jornada laboral. Sin que la empresa garantice que dicho aseo se realice dentro de su jornada efectiva de trabajo, tal y como reconoce el RD 664/1994"*. Por consiguiente, las personas

³⁵ Óp. Cit. *Boletín Oficial del Estado*. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021,...

trabajadoras han de abandonar sus puestos de trabajo cuando finalicen su jornada laboral no cumpliéndose los 10 minutos regulados en el Real Decreto citado. De otro lado, la prueba testifical es una prueba que no confluye en este punto, dado que el precepto manifiesta que son pruebas documentales y periciales, las que han de tenerse en cuenta.

La parte recurrente manifiesta en su escrito la adición de un nuevo hecho con la redacción siguiente: *“Que los trabajadores de la residencia abandonan sus puestos de trabajo una vez finalizada su jornada laboral, realizando su aseo personal, en su caso, fuera de la jornada laboral. Sin que la empresa garantice que dicho aseo se realice dentro de su jornada efectiva de trabajo, tal y como reconoce el Real Decreto 664/1997”*. La parte recurrida manifiesta que la plantilla cuando abandonan sus puestos de trabajo, tras concluir su turno de trabajo, no cumple con los 10 minutos regulados en el artículo 7.2 del RD 664/1997. En todo caso, es un presunto incumplimiento de la Residencia, es una cuestión que no ha sido recogida en ningún acta del Comité de Seguridad y Salud tampoco ha sido denunciada ni a la Inspección de Trabajo, ni a los Tribunales. Y resulta que la parte recurrente lo quiere traer a este procedimiento.

La misma Delegada de Prevención ha manifestado que tiene la posibilidad de lavarse las manos todas las veces que deseen durante la jornada laboral. Del mismo modo, la Médica y Directora Asistencial de la Residencia manifestó en Sala que “si una persona trabajadora realiza una intervención, después me tengo que lavar las manos por ello da tiempo a efectuar tal limpieza”. Es más, la Médica y Directora Asistencial propuso a la Dirección de la Residencia poner a una persona que supervisara y controlara si se realizan esas acciones. Y, actualmente, hay una persona que además de controlar y supervisar lleva a cabo la formación a la plantilla para que sepan la higiene que se tiene que realizar y como colocar los EPIs.

Hasta ahora, todo lo manifestado por la empresa acredita, fehacientemente, que se ha aportado a la plantilla la formación, información, y realización por parte de la plantilla de la higiene de manos. Además, la propia Delgada de Prevención dispuso que conocía los 5 momentos obligatorios de higiene de manos y, por consiguiente, tenía conocimiento de los 5 momentos obligatorios de higiene de manos, explicados detalladamente en el Anexo 5.

Nuevamente, se ha de resaltar que la infografía se explica los tipos de lavado de manos, cuándo corresponde cada uno de ellos y cómo deben realizarse: lavado higiénico de manos y/o asepsia de manos y/o antisepsia quirúrgica. Asimismo se recoge la obligación del personal de realizar un lavado higiénico de manos tanto antes de iniciar la jornada de trabajo, y al finalizarla como antes y después de comer”. En efecto, la testigo aportada por el Sindicato ELA ha manifestado que la empresa les dio formación, que conocía las medidas higiénicas así como tenían conocimiento de la existencia de un bote de gel hidro-alcohólico; en los carros de pañales, mantenimiento, curas, limpieza entre otros. Por consiguiente, el mismo juzgador “a quo” concluye lo siguiente: *“Cuarto: La irrupción de la pandemia habría motivado el establecimiento de protocolos específicos, así como la distribución de preparados alcohólicos a lo largo de todo el centro. Se habría adoptado un protocolo con instrucciones para la desinfección de manos que aquí se da por reproducido”*. Por lo expuesto, el juzgado “a quo” desestimo la pretensión

pretendida por la parte demandada, ahora recurrente, quedando acreditado lo que a continuación se expone:

- Las trabajadoras conocen la infografía de los 5 momentos³⁶ del lavado de manos (incluyendo a la propia Delegada de Prevención), y no sólo la conocen, sino que la plantilla realiza la higiene de manos durante la jornada de trabajo en numerosas y diferentes ocasiones.
- La plantilla están formadas e informadas de todos los riesgos existentes en sus puestos de trabajo así como adoptan las medidas higiénicas que requiere cada situación.

A lo anterior hay que añadir otro hecho nuevo “*Que los trabajadores de la residencia no disponen de lugar específico para realizar el descanso diario, lo realizan en el office o en los vestuarios, sin que la empresa garantice la limpieza de manos ni los 10 minutos tal y como reconoce el Real Decreto 664/1997 y su evaluación de riesgos*”. Sin embargo, esta afirmación no es cierta puesto que ha quedado acreditado que las trabajadoras, realizan de forma continuada la higiene de manos. Es intrascendente para el fallo de la sentencia puesto que se ha acreditado que las personas trabajadoras, descansan y tienen más de un lugar para hacerlo.

Y, por último, una prueba testifical el cual es un medio probatorio que está dentro del artículo 193 b) LRJS³⁷. La Sentencia de instancia que se pretende impugnar, y la Residencia Jaizkibel, tienen el mismo criterio en tanto en cuanto no procede la aplicación de los 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el centro de trabajo. Por consiguiente, las medidas que plantea la empresa amplían las medidas preventivas reguladas en el Real Decreto, ya citado.

Por ello, se ha prestar especial consideración a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao, en fecha 13 de febrero de 2019, la cual fue íntegramente confirmada por la Sentencia nº 1442/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 16 de julio de 2019 (Residencia Bizkotzalde, Babesten S.L y Aztertzen Servicios Asistenciales S.L)³⁸. En ambas resoluciones judiciales concluyeron que el receso establecido en el artículo 7.2 del RD 664/1997 el cual no puede disfrutar el personal con jornada continuada sino que, únicamente, la interrupción de la jornada para comer a las personas trabajadoras con jornada partida. Por consiguiente, el tiempo para el aseo personal previo a la comida está dentro de la interrupción de la jornada para ese menester y no se extiende al personal con jornada continua. El descanso que disfruta el personal de jornada continua esta, únicamente, pensado para la ingesta de alimento, tomar un café, descanso físico, ocio intelectual, la conversación o cualquier otra posibilidad que se considere oportuna y el artículo 7.2 RD 664/1997 no contempla esos 10 minutos para otros supuestos que no sean la comida o el abandono por concluir la jornada laboral.

No obstante, para realizar ese descanso las personas trabajadoras tiene diversos lugares como el Office de planta o en el pasillo, sin embargo de todos

³⁶ Anexo 5: Se adjunta infografía de los 5 momentos de higiene de manos.

³⁷ Óp. Cit. *Boletín Oficial del Estado*. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021,...

³⁸ *Cendoj.* (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/556fe40215aed49d/20191011>

los lugares que disponen, en el vestuario no lo realizan tal y como ha manifestado la parte recurrente. Además, la parte recurrente manifiesta que los lugares de descanso como es el Office o el vestuario, existe un riesgo de exposición a agentes biológicos y cuestionar la salubridad de dichos lugares, se trata de una manifestación carente de fundamento legal. Sobre todo, porque en las evaluaciones de riesgos laborales no está regulado el riesgo de exposición a agentes biológicos, por lo que no existe. Con todo, las evaluaciones de riesgos disponen la obligación de limpieza personal antes de consumir alimento, bebida o tabaco y evitar la aplicación de cosméticos en el lugar de trabajo.

En la jurisprudencia mayoritaria dispone que en el sector de las residencias la exposición a agentes biológicos es una cuestión incidental al propósito principal del trabajo.

Por último, hay que señalar el artículo 193 c) de LRJS en la que no infringe las normas sustantivas ni de la jurisprudencia por lo que hay una inexistencia de la vulneración de tal precepto. La parte recurrente manifiesta que hay una vulneración de los artículos 4 y 7 del RD 664/1997 así como la infracción de la Sentencia nº 1032/2017, de 2 de mayo, sentencia nº 1767/2018 de 13 de noviembre, nº 856/2019 de 7 de mayo de 2019³⁹ y nº 1092/2019 de 4 de junio de 2019⁴⁰ del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin embargo, la jurisprudencia que ha aludido la parte recurrente, el Tribunal ha dado un giro al artículo 7.2 del RD 664/1997 el cual ha manifestado que la empresa supera ampliamente lo dispuesto en dicho precepto. El Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia recurrida, concluye que no hay que considerar que los 10 minutos, a los que se refiere el precepto, tengan como objeto un aseo genérico que resulta evidente que no se encuentra orientado a contener el riesgo. La reciente jurisprudencia ha manifestado que las medidas que adopta la empresa superan ampliamente lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997.

En resumen, los argumentos, mencionados en líneas precedentes, se encuentran avalados con las siguientes sentencias que se adjuntan como Anexo 6 a modo de jurisprudencia ilustrativa. Entre ellas se encuentran la Sentencia Nº 207/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 (autos nº 161/2021) en fecha 4 de junio de 2021 ELA –EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA contra Asociación Urgatzi para la promoción del Bienestar y Comité de empresa de la Residencia San José Etxe Alai; la Sentencia nº 592/2021 de fecha de 23 de marzo de 2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao en fecha 17 de julio de 2020 (Residencia Aita Menni); la Sentencia de Osakidetza: Sentencia nº 1649/2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 15 de diciembre de 2020. La sala desestima íntegramente la demanda de conflicto colectivo promovida por ELA, SATSE, LAB, CCOO, UGT y ESK frente a Osakidetza y, por último, la

³⁹ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f4ec87c982ce3dac/20190726>

⁴⁰ Cendoj. (s.f.). Recuperado el 15 de septiembre de 2021, de <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68a8e4ea66f37a8a/20190828>

Sentencia nº 1092/2019 de fecha de 4 de junio de 2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Residencia "Santa Casa de Misericordia").

VIII. Recomendaciones que se proponen al cliente⁴¹

Por todo lo expuesto, el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante el Tribunal Supremo. Para ello, podemos basar nuestro recurso con el siguiente fundamento haciéndonos valer del artículo 219.1 de la LRJS, ya citado. En virtud de la Sentencia nº 3110/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sede en Málaga de fecha 3 de marzo de 2016 y Sentencia nº 3068/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sede en Málaga de fecha 3 de marzo de 2016. Ambos procedimientos fueron incoados por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores frente al Servicio Andaluz de Salud dictando Sentencia por el Juzgado de lo Social nº9 de Málaga. En ambos casos se estiman el recurso de suplicación en el que el Sindicato UGT solicitaba la medida de 10 minutos de aseo personal antes de la comida y de otros 10 antes de abandonar el trabajo; tal y como está regulado en el Real Decreto 664/1997.

Sendas resoluciones relatan que *“en desarrollo del RD 664/1997 se dictó por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo una Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, que contiene en beneficio de los trabajadores menciones específicas y reglas adicionales de protección en función de las tareas profesionales a realizarse en cada caso particular y agentes vinculados a las mismas, que vienen a no sujetarse exactamente a los parámetros de los apartados 2º y 3º del artículo anteriormente citado que, por ello, han de entenderse son estándares mínimos de protección que por ende no han necesariamente de ser cumplidos exactamente en todo momento, cuando los aplicados mejoran y son más eficaces que aquéllos”* Continúa diciendo la Sentencia que *“...consta acreditado por la documental aportada que la demandada tiene establecidas en el hospital específicas medidas de higiene de sus empleados, como el distintivo manos seguras y la higiene de manos tras la atención de cada paciente, por lo que no solamente no limita a los trabajadores el que puedan disponer de 10 minutos de aseo antes de la comida y antes de marcharse, sino que viene a incitar y a fomentar que tal higiene sea llevada a cabo continuamente, durante su jornada laboral, cada vez que lo requiera la práctica asistencial, y ello en cumplimiento y seguimiento de los dictados de la Guía Técnica oficial anteriormente indicada”*. De la misma forma continúa diciendo que *“Ligado a lo anterior, y en relación a la pretensión acogida atinente a que se provea a los trabajadores de lugares adecuados para guardar de forma diferenciada la ropa de trabajo y la de calle, resulta de los términos de la misma sentencia recurrida que la empresa cumple con los parámetros dictaminados en el artículo 7.3º del RD de constante referencia, cuando no solo los trabajadores tienen a su disposición equipos de protección individual desechables, sino máxime cuando resulta que la demandada asume diariamente la limpieza y desinfección de todas las prendas de trabajo de los*

⁴¹ Palomar Olmeda, A. (2021). Practicum Ejercicio de la Abogacía. Thomson Reuters.

empleados que pudieran estar contaminadas por agentes biológicos, por lo que es innegable el que los mismos no necesitan bajo ningún concepto guardar las mismas en lugar alguno, y mucho menos en un espacio donde se ubiquen sus propias prendas de calle”.

Por otro lado, se ha de prestar especial consideración a la Sentencia 652/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sede de Sevilla de fecha de 2 de febrero de 2007 que dispone que en su único fundamento de Derecho “*La parte actora solicita en su demanda que se declare el derecho de los trabajadores, que durante su jornada estén expuestos a agentes biológicos, a disponer dentro de su jornada laboral de diez minutos para el aseo antes de abandonar el trabajo, basándose en lo expuesto en el artículo 7º.2) del Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, el cual, efectivamente, expresa, refiriéndose a las actividades en que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, que “los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.”; y, en principio, esta norma es de indudable aplicación a los demandantes, pero en el presente caso esta medida, que puede considerarse mínima, está ampliamente superada por la actuación empresarial, porque la misma considera necesario, y así lo establece en los protocolos específicos para la prevención de riesgos biológicos y manejo de equipos de protección individual, que el aseo personal se efectúe siempre que se produzca una atención sanitaria, de manera que, cuando se está en situación de disponibilidad, se esté perfectamente aseado y preparado para una nueva actuación, con lo cual se puede dar la circunstancia de que el aseo se produzca varias veces en la jornada de trabajo, aseo que no está sujeto a tiempo límite, sino que es el necesario para que se esté en condiciones de atender a un nuevo servicio de asistencia sanitaria, y únicamente cuando se concluye esta actividad de aseo, de reposición y de limpieza, es cuando se comunica al centro de coordinación la situación de disponible del equipo de emergencia, por lo que, si termina la jornada laboral en situación de disponibilidad, los trabajadores se encuentran perfectamente aseados sin necesidad de volver a asearse, y si coincide el final de la jornada con la atención a pacientes, se sigue prolongando la jornada de trabajo, no hasta que termina la actuación sanitaria, sino hasta que, después de ésta, se encuentra de nuevo perfectamente aseado y preparado el equipo de emergencia, y por tanto lo dispuesto en el artículo 7º.2 se cumple, e incluso queda ampliamente superado por el sistema de funcionamiento de EPES y por los mecanismos establecidos de control de riesgo, y, si el personal de la empresa demandada procede de forma sistemática, exhaustiva y protocolizada a su descontaminación y desinfección después de cada servicio sanitario y por el tiempo necesario sin limitación, la aplicación formalista de la exigencia de los diez minutos de aseo personal antes de finalizar la jornada carece indiscutiblemente de lógica alguna, por lo que, al cumplirse perfectamente lo dispuesto en el Real Decreto citado, la demanda debe ser desestimada, máxime que además el artículo 4º, que establece la obligación de proceder a la evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, señala que “si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo, pero puede provocar la*

exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5º al 13º de este Real Decreto , salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario", y hay que tener en cuenta que la evaluación de riesgos señala como nivel de probabilidad del riesgo "bajo" (tres sobre diez), y en cuanto a la ponderación de riesgo, presenta un nivel nueve sobre cien, que equivale a su consideración de "tolerable", es decir que no se necesita mejorar la acción preventiva, y por tanto sería inaplicable lo dispuesto en los artículos 5º al 13º del Real Decreto, por innecesarios acogiendo precisamente a la citada norma, por lo que, como se dijo, la demanda debe ser desestimada".

Del mismo modo la Sentencia nº 1032/2017 del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de fecha 2 de mayo de 2017 en el que se desestima el recurso de suplicación *"Y en lo que hace a la medida de los 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y de otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo, estando la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 664/1997 como disposición mínima aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral, situación en la que se encuentran los afectados por el presente conflicto colectivo (la propia recurrente reconoce que desarrollan la actividad de asistencia sanitaria prevista en el anexo I del RD, sin que cuestione el hecho probado quinto cuando dice que corren el riesgo de contagio por enfermedades infecto-contagiosas), sin que en este caso opere la excepción a su aplicabilidad prevista en el art. 4.5 del RD cuando recoge que se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 del RD "salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario", porque, al contrario de lo que entiende la recurrente, la evaluación de riesgos no dice que esa medida sea innecesaria, sino que no tiene sentido la estricta aplicación de 10 minutos para el aseo antes de la comida y al abandonar el trabajo, y sin que tampoco pueda prevalecer la opinión del técnico de prevención que lo haya emitido -por mucho que coincida con lo contemplado en la Guía Técnica elaborada por orden de la DF 1ª del RD 644/1997, que, no olvidemos, carece de carácter vinculante- sobre una disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados, debemos igualmente rechazar la oposición a la aplicabilidad a los mismos de esta medida".*

IX. Conclusiones finales

PRIMERA: Agentes biológicos: definición, clasificación y transmisión

Los agentes biológicos se definen como microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Los riesgos más frecuentes como consecuencia de las exposiciones a agentes biológicos, son las enfermedades infecciosas. Por consiguiente, una infección se define como el resultado del establecimiento e interacción de un microorganismo en un organismo que actúa como huésped del mismo. Los agentes biológicos se clasifican en 4 importantes grupos los cuales son virus, bacterias, hongos y parásitos. Del mismo modo, es importante prestar especial consideración a la forma de transmisión de los agentes biológicos y es que se transmiten por el aire, por bioaerosoles, mediante el agua o alimentos, por contaminación de superficies, herramientas u objetos así como por medio de otros seres vivos.

SEGUNDA: Obligaciones del empresario: normativa de aplicación

Los empresarios deben de elaborar la evaluación de riesgos laborales de cada puesto de trabajo tal y como viene regulado en el artículo 16.1 y 2 de LPRL. Dicha evaluación se debe de integrar en el sistema de toda la empresa, es decir, se tiene que incluir en todas las actividades y niveles jerárquicos.

El plan de riesgos laborales incluirá una estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos así como los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. Del mismo modo, el artículo 41.1 del V Convenio Colectivo Sectorial del Centros de la Tercera Edad de Bizkaia manifiesta que el personal tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, el artículo 4.5 del RD 664/1997 dispone que si los resultados de la evaluación de riesgos revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo. Sin embargo, puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario.

Por otra parte, el artículo 4.3 RSP señala que la evaluación de los riesgos se ha de realizar por medio de la intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de este Reglamento. De tal forma, se deberá de repetir la evaluación de forma periódica y cuando haya algún cambio de las condiciones que afecten a las personas trabajadoras.

TERCERA: Artículo 7.2 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes durante el trabajo.

El artículo 7.2 del RD 664/1997 manifiesta que los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. Sin embargo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo han dispuesto en su numerosa jurisprudencia que el precepto es una disposición mínima y el empresario podrá tomar las medidas que sean necesarias. Igualmente, la normativa del año 1997, a día de hoy, ha quedado obsoleta, por

ello es necesario el planteamiento de otras medidas que cubran los riesgos de la plantilla.

CUARTA Procedimiento a seguir para la prevención y control de la COVID-19 en los centros residenciales.

Todo lo expuesto hasta ahora ha sido incrementado por la aparición de la Covid-19. Como consecuencia de ello, la empresa se vio en la necesidad de realizar un Plan General de Intervención de convivencia con la Covid. En ese Plan se desarrollan una serie de medidas para que realicen los profesionales de los centros socio-sanitarios.

QUINTO.- Exposición del caso: Residencia Jaizkibel

Concretamente, se explica el caso de la Residencia Jaizkibel en la que el conflicto colectivo afecta a las personas trabajadoras de enfermería, fisioterapeuta, médicos, gerocultor, trabajador social, personal de mantenimiento y psicología. En particular, la parte demandante solicita la aplicación en la residencia de los 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el centro de trabajo regulados en el artículo 7.2 del RD 664/1997. Es más, el artículo 4.5 del Real Decreto 664/1997 manifiesta, en su texto literal, que *“Si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo pero puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario”*. La jurisprudencia ha dispuesto que el artículo 7.2 del RD 664/1997 es una disposición mínima, y la empresa puede tomar medidas que amplíen con creces lo dispuesto en tal precepto. De igual forma, es importante señalar que la normativa es del 1997, y ha quedado obsoleta en tanto en cuanto la mercantil ha desarrollado medidas, que superan ampliamente lo dispuesto en dicha normativa.

De otro lado, cabe preguntarse si se aplica de igual forma en caso de que haya personal con jornada continuada o partida. La jurisprudencia es clara, el precepto no puede extenderse al tiempo de descanso del que disfrutaban las personas trabajadoras con jornada continuada. Por lo tanto, la interrupción de la jornada para comer, se extendería, únicamente, a la plantilla con jornada partida.

Como colofón, el juez dictó sentencia desestimando la pretensión de la parte demandante. Y, es por ello, que interpone el Recurso de Suplicación que, a día de hoy, no hay respuesta.

SEXTO.- Recomendaciones que se proponen al cliente

En el caso de que estime el recuro de Suplicación interpuesto por la parte actora tenemos la posibilidad de interponer el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante el Tribunal Supremo. Para ello se emplea Sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia.

Bibliografía

➤ Doctrina

- *FREMAP*. (2021). Recuperado el 7 de octubre de 2021, de <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.056%20-%20M.S.S.%20Residencias%20Tercera%20Edad.pdf>
- *Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo*. (s.f.). Recuperado el 10 de septiembre de 2021, de <https://www.insst.es/-/como-se-transmiten-los-agentes-biologicos-y-entran-en-contacto-con-el-trabajador%20->
- Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2014). *Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos*. Recuperado el 7 de septiembre de 2021, de https://www.insst.es/documents/94886/96076/agen_bio.pdf/f2f4067d-d489-4186-b5cd-994abd1505d9
- José, A. d. (26 de octubre de 2020). *Coronapedia*. Recuperado el 7 de octubre de 2021, de <https://www.coronapedia.org/base-conocimiento/colocacion-y-retirada-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-frente-a-covid-19/>

➤ Normativa

- *Boletín Oficial de Bizkaia*. (18 de febrero de 2018). Recuperado el 7 de septiembre de 2021, de https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/02/09/III-26_cas.pdf?hash=916adffb5df813ffa4a27cb78dcb274d
- Boletín Oficial de Bizkaia (18 de febrero de 2018). Recuperado el 7 de septiembre de 2021 https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/02/09/III-26_cas.pdf?hash=a6729e1317fe8fc165cb8ee8e7bf58ac
- *Boletín Oficial del Estado*. (24 de marzo de 2021). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4568&p=20210324&tn=2>
- *Boletín Oficial del Estado*. (11 de octubre de 2011). Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936>
- *Consejo General de la Abogacía Española*. (27 de febrero de 2009). Recuperado el 9 de octubre de 2021, d de https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/reglamento_procedimiento_disciplinario_pdf.pdf

- *Consejo General de la Abogacía Española*. (2019). Recuperado el 9 de octubre de 2021, de <https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/05/Codigo-Deontologico-2019.pdf>

➤ **Jurisprudencia**

- Sentencia nº rec 953/1991 del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1991
- Sentencia nº 652/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede en Sevilla de 2 de febrero de 2007
- Sentencia nº 1032/2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 2 de mayo de 2017
- Sentencias nº 1767/2018 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 25 septiembre 2018,
- Sentencias nº 2240/2018 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de noviembre,
- Sentencia nº 3068/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Málaga de 14 de abril de 2016
- Sentencia nº 3110/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede en Málaga de marzo de 2016
- Sentencia del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao en fecha de 13 de febrero de 2019 la cual fue confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 16 de julio de 2019
- Sentencias nº 475/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 26 de febrero de 2019,
- Sentencias nº 856/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de mayo de 2019
- Sentencia nº 1767/2018 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de noviembre
- Sentencias nº 856/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de mayo de 2019
- Sentencias nº1092/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 4 de junio de 2019
- Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao, en fecha 13 de febrero de 2019, la cual fue íntegramente confirmada por la Sentencia nº 1442/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 16 de julio de 2019 (Residencia Bizkotzalde, Babesten S.L y Aztertzen Servicios Asistenciales S.L)
- Sentencia nº 1092/2019 de fecha de 4 de junio de 2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Residencia "Santa Casa de Misericordia").
- Sentencia nº 139/2019 del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2019
- Auto de la Sala del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2020
- Sentencia nº 1649/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 15 de diciembre de 2020 se desestima la demanda interpuesta por ELA, SATSE, LAB, CCOO, UGT y ESK frente Osakidetza.

- Sentencia nº 592/2021 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha de 23 de marzo de 2021(Residencia Aita Menni) por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Bilbao de fecha 17 de julio de 2020
- Sentencia nº 251/2021 del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao de fecha 9 de junio de 2021
- Sentencia Nº 207/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 (autos nº 161/2021) en fecha 4 de junio de 2021 ELA –EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA contra Asociación Urgatzi para la promoción del Bienestar y Comité de empresa de la Residencia San José Etxe Alai.

ANEXOS

Índice

Anexo 1 imágenes de cómo han de proceder para su colocación y retirada.....	1
Anexo 2 las evaluaciones de riesgos se recogen de forma resumida.....	2
Anexo 3 La mercantil ha adoptado todas las medidas que ha considerado necesarias con la aprobación de los siguientes protocolos todos ellos anteriores al COVID 19.....	5
Anexo 4 Jurisprudencia ilustrativa: Tribunal Superior de Justicia de 25 de septiembre de 2018 que remite a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de mayo de 2017, sentencia del 13 de noviembre de 2018, sentencia nº 475/2019, de 26 de febrero y sentencia nº 856/2019 de 7 de mayo de 2019....	9
Anexo 5 Se adjunta infografía de los 5 momentos de higiene de manos.....	17
Anexo 6 jurisprudencia ilustrativa.....	18

Anexo 1: Colocación y retirada de los Equipos de Protección Individual⁴²

PUESTA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



UNIÓN DE MUTUAS
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 267

PASOS PARA PONERSE LOS EPIS

1. Tener claro los EPI que debemos utilizar para la tarea. Preparar los materiales adicionales (ej. contenedor de residuos)



2. Ponte la bata, de forma que cubra totalmente el cuerpo (abrochada), incluidos los brazos.



3. Ponte la mascarilla FFP2/FFP3. Comprueba el correcto ajuste de la mascarilla. Ponte la protección ocular (gafas de montura integral).



4. Ponte los guantes (por encima de los puños de la bata).



PASOS PARA QUITARSE LOS EPIS

1. Al retirar los EPI evita su contaminación, la de otras personas y del medio ambiente. Retirar los guantes y la bata. Enrollar sobre sí mismo. Retirar al contenedor adecuado.



2. Realiza estricta higiene de manos.



3. Retira las gafas (protección ocular) desde la parte de atrás (goma de sujeción). Retira la mascarilla desde la parte de atrás (goma de sujeción). Retira estos equipos de forma adecuada (limpieza/residuo)



4. Realiza estricta higiene de manos



⁴² Unión de mutuas (Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 267). (s.f.). Recuperado el 28 de octubre de 2021 , de <https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/03/Cartel-EPIS.pdf>

Anexo 2: Evaluaciones de riesgos

- ❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Médico, de fecha 1 de abril de 2019.
 - Aplicar normas de higiene personal antes y después de la atención a cada residente, aunque se empleen guantes, utilizando agua y jabón líquido o soluciones hidro-alcohólicas disponibles en baños comunes y zonas de control, con las indicaciones de uso y modo de lavado de manos.
 - Se recomienda la aplicación del tiempo necesario para su higiene personal en función de la tarea realizada y del agente biológico quedando recogido en procedimiento interno de la empresa
 - Lavarse las manos, entre otras, tras quitarse los guantes, al comenzar y al finalizar la jornada laboral.

- ❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Enfermería, de fecha 1 de abril de 2019.
 - Aplicar normas de higiene personal antes y después de la atención a cada residente, aunque se empleen guantes, utilizando agua y jabón líquido o soluciones hidro alcohólicas disponibles en baños comunes y zonas de control, con las indicaciones de uso y modo de lavado de manos
 - Se recomienda la aplicación del tiempo necesario para su higiene personal en función de la tarea realizada y del agente biológico quedando recogido en procedimiento interno de la empresa.
 - Lavarse las manos, entre otras, tras quitarse los guantes, al comenzar y al finalizar la jornada laboral.

- ❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Gerocultor/a, de fecha 1 de abril de 2019.
 - Aplicar normas de higiene personal antes y después de la atención a cada residente, aunque se empleen guantes, utilizando agua y jabón líquido o soluciones hidro alcohólicas disponibles en baños comunes y zonas de control, con las indicaciones de uso y modo de lavado de manos.
 - Se recomienda la aplicación del tiempo necesario para su higiene personal en función de la tarea realizada y del agente biológico quedando recogido en procedimiento interno de la empresa.
 - Lavarse las manos, entre otras, tras quitarse los guantes, al comenzar y al finalizar la jornada laboral.

- ❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Fisioterapeuta, de fecha 19 de octubre de 2015.

- Aplicar normas de higiene personal antes y después de las atenciones a cada residente, aun cuando se empleen guantes, utilizando agua y jabón liquido de envases no rellenables así como desinfectantes.
- Limpieza personal antes de ingerir alimentos, bebida o tabaco, así como evitar la aplicación de cosméticos en el lugar de trabajo.
- Disponen de desinfectantes oculares y cutáneos en el lugar de trabajo.

❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Psicólogo/a, de fecha 19 de octubre de 2015.

- Aplicar normas de higiene personal antes y después de la atención a cada residente, aun cuando se empleen guantes, utilizando agua y jabón liquido de envases no rellenables así como desinfectantes.
- Limpieza personal antes de ingerir alimentos, bebida o tabaco, así como evitar la aplicación de cosméticos en el lugar de trabajo.
- Disponen de desinfectantes oculares y cutáneos en el lugar de trabajo.

❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Trabajador/a social, de fecha 19 de octubre de 2015.

- Aplicar las normas de higiene personal antes y después de las atenciones a cada paciente, aun cuando se empleen guantes, utilizando agua y jabón liquido de envases no rellenables así como desinfectantes.
- Limpieza personal antes de ingerir alimentos, bebida o tabaco, así como evitar la aplicación de cosméticos en el lugar de trabajo.
- Disponen de desinfectantes oculares y cutáneos en el lugar de trabajo.

❖ Evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo de Mantenimiento, de fecha 19 de octubre de 2015.

- Las personas trabajadoras desempeñan los trabajos de fontanería y limpieza de alcantarillado de fecales (no visible) con caña y agua. Asimismo, puede realizar trabajo de jardinería de forma puntual. La actividad descrita no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos, se ha de considerar la posible exposición a agentes biológicos de los grupos 2 y 3.
- Realización de evaluaciones higiénicas de exposición a agentes biológicos periódicamente, en función de los resultados obtenidos y/o cambio de las condiciones de trabajo que puedan afectar a la exposición de los trabajadores a los agentes biológicos.
- En el caso de que haya detectado que alguien de la plantilla se ha contagiado con un patógeno, se realizara de nuevo la evaluación de riesgos.

- Agentes biológicos grupos 3 y 4 está presente una persona, como recurso preventivo, durante el tiempo que duren los trabajos. Tendrá una formación mínima de Técnico de Prevención de Nivel Básico.
- Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural si está expuesta a agentes biológicos de los grupos de riesgos 2, 3 y 4, se tiene que consultar a Vigilancia de Salud, pues puede influir negativamente en la salud de la trabajadora. No desarrollan actividades que supongan un riesgo para su salud salvo que este inmunizada.

Anexo 3 La mercantil ha adoptado todas las medidas que ha considerado necesarias con la aprobación de los siguientes protocolos todos ellos anteriores al COVID 19

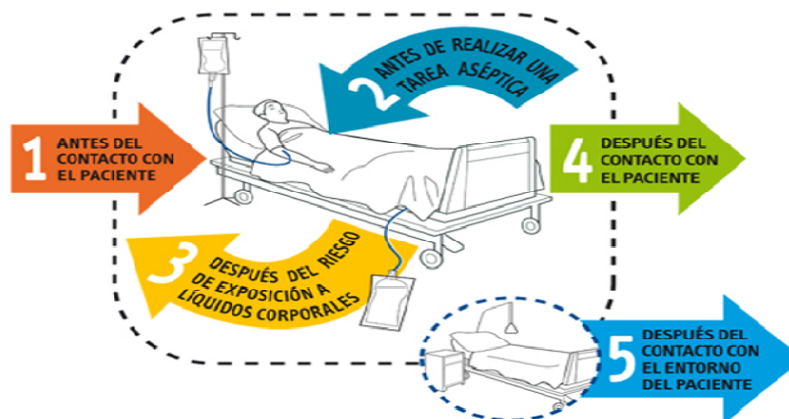
A continuación se va a proceder a realizar un breve resumen de alguno de los documentos señalados con anterioridad:

1) Protocolo de higiene de manos para los profesionales sanitarios, de fecha 21 de marzo de 2018.

En dicho documento, dirigido a todos los profesionales sanitarios IMQ-IGURCO (médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, etc.), se recoge la importancia de una correcta higiene de manos, así como los 5 momentos principales en los que debe realizarse dicho lavado:

1. Antes del contacto con el paciente,
2. Antes de realizar una tarea aséptica,
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales,
4. Después del contacto con el paciente y, por último,
5. Después del contacto con el entorno del residente incluso aunque no haya tocado al residente.

En efecto, todos estos momentos están recogidos en una infografía repartida por diferentes lugares de la residencia. Las personas trabajadoras tienen conocimiento de dicha infografía de la forma que se tiene que proceder antes y después de haber entrado en contacto con un residente. La infografía que está repartida por la residencia es la que consta a continuación:



En definitiva, el lavado de manos se deberá de realizar conforme lo dispuesto en la Infografía anterior y, concretamente, el proceso consta de los siguientes 5 momentos:

1. **Antes del contacto con el residente.** Por ejemplo: antes de realizar una exploración clínica, de determinar el pulso y la tensión arterial o antes del contacto físico directo con el residente para ayudarle a moverse.

2. **Antes de realizar una tarea aséptica.** Por ejemplo: antes del contacto con mucosas o piel intacta, de la inserción de dispositivos médicos, de la cura de heridas o de la preparación de materia o comidas.
3. **Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.** Por ejemplo: después de estar en contacto con dermatitis, de la inserción de dispositivos médicos, de la extracción o manipulación de cualquier muestra líquida o de la limpieza de orina, heces o vómitos.
4. **Después del contacto con el residente.** Por ejemplo: después de una exploración clínica, de determinar el pulso y la tensión arterial o después del contacto físico directo con el residente para ayudarle a moverse.
5. **Después del contacto con el entorno del residente, incluso aunque no haya tocado al residente.** Por ejemplo: después de una visita médica.

Del mismo modo, dicho protocolo manifiesta que será de obligado cumplimiento el lavado de manos en las siguientes circunstancias:

- Antes de iniciar la jornada laboral y al finalizarla.
- Siempre que las manos estén sucias o contaminadas con materia orgánica, sangre u otros fluidos corporales.
- Después del contacto con fluidos o excreciones corporales, mucosas, piel no intacta y apósitos de herida.
- Antes y después de comer.
- Después de ir al aseo.
- Después de estornudar, sonarse...
- Antes del contacto directo con los residentes.
- Después del contacto directo con piel intacta del residente, por ejemplo cuando se toma el pulso, la presión arterial o se moviliza un residente.
- Antes de ponerse y después de quitarse los guantes.
- Cuando al realizar los cuidados a un residente se pasa de un área del cuerpo contaminada a una limpia.
- Después del contacto con objetos que están situados cerca del residente, incluyendo los equipos médicos y material sanitario.
- En los casos que se sospecha o está confirmada la exposición al *Bacillus anthracis* y *Clostridium difficile*, está recomendada la acción mecánica del lavado y aclarado dado que los alcoholes, Clorhexidina, yodóforos y otros antisépticos, tienen escasa actividad frente a esporas.

Además de todo lo expuesto hasta este momento, la residencia de Jaizkibel cuenta con 65 dispensadores de hidrogel, colocados de la forma

siguiente: 18 dispensadores en la planta baja, mínimo 1 dispensador por cada servicio, 1 dispensador dentro de cada ascensor, 1 en cada carro de enfermería, 1 en el carro de personal de mantenimiento entre otros.

2) Protocolo de aislamiento de junio de 2017, cuya revisión de octubre de 2020 está aprobada en noviembre de 2020.

En este protocolo se recoge la necesidad de lavarse las manos con frecuencia, así como la manera en la que ha de realizarse dicho lavado. Concretamente, dicho protocolo establece que *“Debe realizarse con frecuencia. Debe hacerse a conciencia tras el contacto con los pacientes o muestras contaminadas, se hayan utilizado o no guantes. Se deben lavar las manos antes de colocarse e inmediatamente después de quitarse los guantes y en el contacto entre pacientes. [...] Se usará un jabón líquido normal no antimicrobiano para el lavado higiénico. El jabón antimicrobiano o antiséptico se utilizará para circunstancias específicas (control de brotes, gérmenes multiresistentes, etc.)”*.

3) Protocolo de prevención y tratamiento de infecciones, de fecha 1 de marzo de 2013

En dicho protocolo se establece las medidas preventivas generales y de aislamiento de las enfermedades infecto contagiosas: lavado de manos, el uso de guantes etc. En particular, su texto literal establece que el lavado de manos *“debe realizarse con frecuencia”*, así como *“es la medida más importante para reducir los riesgos de transmisión. Debe hacerse a conciencia tras el contacto con los residentes/usuarios o muestras contaminadas, se lleven o no puestos guantes. Se deben lavar las manos inmediatamente después de quitarse los guantes y en el contacto entre residentes/usuarios. Puede ser necesario entre procedimientos en el mismo residente/usuario”*.

Las medidas generales para la utilización de guantes y lavado de manos para los profesionales sanitarios los cuales *“deben lavarse las manos antes de realizar cualquier manipulación o instrumentalización después del contacto con residente/usuarios portadores. Esta medida está considerada como la más eficaz y fundamental”*. Asimismo está establecido un protocolo concreto frente al Estafilococos Aureus Resistentes a la Meticilina (SARM): *“los profesionales sanitarios deben lavarse las manos antes de realizar cualquier manipulación o instrumentalización y después del contacto con residente/usuario portadores, siempre con el desinfectante indicado por el servicio médico”*. Además de otra documentación asociada a las campañas que desarrolla Osakidetza.

4) Protocolo concreto frente al Estafilococos Aureus Resistentes a la Meticilina (SARM), de abril de 2016:

Se establecen medidas preventivas estándar de transmisión por contacto como es la higiene de manos. Para ello, deberá de utilizarse jabón o solución hidro-alcohólica.

5) Protocolo frente a la Gripe de abril de 2016 dentro del cual se desarrolla el Protocolo frente a la Gripe A.

Se establecen medidas preventivas para la transmisión por contacto entre las cuales se encuentran la higiene de manos. Además, de sustituir *“el jabón normal por jabón antiséptico o solución hidro-alcohólica, lavarse las manos tras el contacto con la persona usuaria o muestras contaminadas y, entre procedimientos en el mismo usuario, se hayan utilizado guantes o no”*.

ANEXO 4 JURISPRUDENCIA A TITULO ILUSTRATIVO

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 25/09/2018, la cual se remitía su vez a una resolución, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 02/05/2017:

[...] estando la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 664/1997 como disposición mínima aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad

laboral, situación en la que se encuentran los afectados por el presente conflicto colectivo [...] sin que en este caso opere la excepción a su aplicabilidad prevista en el

artículo 4.5 del RD cuando recoge que se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 del RD “salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario”, porque, al contrario de lo que entiende la recurrente, la evaluación de riesgos no dice que esa medida sea innecesaria, sino que no tiene sentido la estricta aplicación de 10 minutos para el aseo antes de la comida y al abandonar el trabajo, y sin que tampoco pueda prevalecer la opinión del técnico de prevención que lo haya emitido -por mucho que coincida con lo contemplado en la Guía Técnica elaborada por orden de la DF 1ª del RD 664/1997, que no olvidemos, carece de carácter vinculante,- sobre una disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados, debemos igualmente rechazar la opción a la aplicabilidad de los mismos de esta medida.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 13 de noviembre de 2018

“Por otro lado, queremos añadir a nuestros razonamientos que la Ley de prevención de Riesgos laborales 31/1995, de 8 de Noviembre EDL 1995/16211, en su artículo 14.2 establece que ‘en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...’.

En el apartado 4 del artículo 15 EDL 1885/16211 señala ‘que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador ‘.

Finalmente, el artículo 17.1 EDL 1995/16211 establece ‘ que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores “.

Del juego de éstos 3 preceptos se deduce, en palabras de la Sentencia del tribunal Supremo de 9 de octubre de 2001 EDJ 2001/49262, ‘ como también

*concluye la doctrina científica, **QUE EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL EMPRESARIO ES INCONDICIONADO Y, PRÁCTICAMENTE, ILIMITADO.***

Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. (...)

Siendo así, debemos afirmar que la medida que el sindicato demandante está reclamando a la empresa demandada tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, y al no tratarse de una medida irracional ni absurda o desproporcionada, debe ser exigible a la demandada por imperativo de la amplia obligación que en esta materia le atribuye la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

Si la propia Evaluación de riesgos laborales contempla como preceptivo el lavado de manos, resulta totalmente justificado y ponderado que el trabajador cuente con un breve periodo de 10 minutos para hacer efectiva esta medida de seguridad y salud antes de comer o de abandonar su puesto de trabajo. La medida que examinamos debe ser implementada por la empresa, precisamente para hacer efectivo y para posibilitar el lavado de las manos al personal, y evitar así cualquier distracción u omisión al respecto de las prisas inherentes a las jornadas de trabajo -artículo 15.4 LRPL-. Y ello porque, como hemos dicho, las obligaciones en materia de seguridad y salud para la empresa no se constriñen a las reglamentariamente establecidas, sino que deben adoptarse las que sean necesarias, con el único límite de su futilidad, irracionalidad o desmesura.

Recordemos en este punto , como colofón a nuestros argumentos, que el trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene, a tenor de lo previsto en el artículo 19 et; y que los propios representantes legales de los trabajadores pueden requerir al empresario para que adopte las medidas oportunas en materia de seguridad, y si la petición no fuese atendida, dirigirse entonces a la autoridad competente – apartado quinto del artículo 19 ET-.Esto es precisamente lo que el sindicato demandante está planteando a través del presente conflicto colectivo, solicitando que por parte de la empresa demandada se implemente la medida que señala el artículo 7.2 del Decreto 644/1997-.

Consideramos que la medida es totalmente razonable, atendiendo al riesgo de contacto con agentes biológicos que tiene estos trabajadores, y que no resulta superflua, sino que se complementa con otras medidas de seguridad, como los guantes o las mascarillas que también menciona la evaluación de riesgos laborales

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 475/2019 de 26 febrero. JUR 2019\166588, del TSJPV:

*"Expuesto el marco normativo de aplicación, decíamos sobre esta medida en nuestra sentencia de 2 de mayo de 2017 antes mencionada y así dijimos también en la posterior de 25 de septiembre de 2018 (recurso 1622/2018) : "la medida que se solicita está contemplada en el artículo 7.2 del RD 664/1997 como **disposición mínima aplicable** a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan **estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral**, situación en la que se encuentran los afectados por el presente conflicto colectivo (la propia recurrente reconoce que desarrollan la actividad de asistencia sanitaria prevista en el anexo I del RD, sin que cuestione el hecho probado quinto cuando dice que corren el riesgo de contagio por enfermedades infecto-contagiosas), sin que en este caso opere la excepción a su aplicabilidad prevista en el art. 4.5 del RD cuando recoge que se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 del RD "salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario", porque, al contrario de lo que entiende la recurrente, la evaluación de riesgos no dice que esa medida sea innecesaria, sino que no tiene sentido la estricta aplicación de 10 minutos para el aseo antes de la comida y al abandonar el trabajo, y **sin que tampoco pueda prevalecer la opinión del técnico de prevención que lo haya emitido** -por mucho que coincida con lo contemplado en la Guía Técnica elaborada por orden de la DF 1ª del RD 644/1997, que, no olvidemos, carece de carácter vinculante- sobre una disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados, debemos igualmente rechazar la oposición a la aplicabilidad a los mismos de esta medida.*

*No alteran lo razonado los informes de la Inspección de Trabajo y de Osalan emitidos en relación a otras residencias sobre las que se desconocen las concretas condiciones de trabajo que se daban en las mismas, siendo significativo que la recurrente destaque el emitido por la Inspección de Trabajo concluyendo la aplicabilidad de las medidas correctoras del RD porque en aquel caso la evaluación del riesgos no las señalaba como innecesarias, puesto que, como ya hemos dicho, **en este caso tampoco se dice en la evaluación de riesgos que sea innecesaria la medida que ahora examinamos, aunque la matice.***

Así, no se deriva lo contrario de lo señalado en la evaluación de riesgos ni del contenido establecido en la Guía Técnica por mor de la DF 1ª del RD (que no es vinculante y solo da una opinión matizada sobre la medida) o en el manual publicado por el sindicato CCOO para el sector (que, sin que nada diga sobre la inaplicabilidad de esa medida, tiene un carácter meramente orientativo), sin que tampoco quepa extraer otra cosa de la actuación de las delegadas de prevención en el seno del Comité de Seguridad y Salud". En el caso que nos ocupa es cierto que en la evaluación específica de riesgos laborales de la residencia demandada de fecha 7 de diciembre de 2016 se contempla el riesgo de exposición a agentes biológicos así como varias medidas preventivas propuestas para cada puesto de trabajo, entre las que se contempla el lavado de manos tras el contagio con sustancias biológicas, así

*como implantar y verificar la implantación de protocolos de actuación en tareas con posible exposición a contaminantes biológicos RD 664/1997- (protección de los trabajadores frente a agentes biológicos). **Y entre las medidas contempladas en el citado Real Decreto están las que ahora se reclaman por los trabajadores.***

Por otra parte dicha medida está indicada en estos casos por la propia Guía Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, si bien no es vinculante."

Y dado que los trabajadores de la empresa demandada reúnen los requisitos de exposición a agentes biológicos previstos en el Real Decreto 664/1997 para la aplicación de la medida controvertida, entendemos que la petición de la parte actora resulta atendible, sin que la empresa pueda oponer que ya adopta otras medidas de protección más eficaces que en su caso serían complementarias.

*Seguir la misma conclusión que en los anteriores procedimientos seguidos en esta Sala no implica aplicar los efectos del instituto de la cosa juzgada (artículo 222 LEC(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)) como argumenta la demandada, sino como dice la sentencia recurrida **"REGLAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, DE LÓGICA RACIONAL Y DE COHERENCIA DETERMINAN QUE SIENDO PRÁCTICAMENTE EL MISMO COLECTIVO AFECTADO, LOS TRABAJADORES DE RESIDENCIAS QUE TIENEN CONTACTO CON AGENTES BIOLÓGICOS, MISMA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA EMPRESA DEMANDADA Y DE CONTENIDO COINCIDENTE LA ESPECÍFICA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN AMBAS RESIDENCIAS, LA CONCLUSIÓN SEA LA MISMA QUE EN LOS AUTOS DE CONFLICTO COLECTIVO"** resueltos por nuestra sentencia de 2 de mayo de 2017 ."*

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección1ª), Sentencia núm. 856/2019 de 7 mayo. JUR 2019\227865

"A) Resultando de las denuncias anteriores que la pretensión inicial de la demanda se ha reducido ahora por los sindicatos recurrentes al reconocimiento del derecho a la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 644/1997 , se señala al efecto que, participando el personal afectado en actividades de atención sanitaria, personal y de higiene a las personas usuarias de la residencia, y estando previsto en el evaluación de riesgos su riesgo a la exposición de agentes biológicos vía sangre, vía aérea, vía fecaloral y vía contacto directo, de conformidad con lo resuelto por las referidas sentencias de esta Sala, debe reconocerse a dicho personal la medida dispuesta como mínima en el art. 7.2 del RD, siendo el lavado de manos a lo largo de la jornada fomentado en la evaluación de riesgos, con alcance inferior al del aseo personal contemplado en el citado artículo con anterioridad a la ingesta de alimentos o al abandono del centro de trabajo, una medida complementaria que no puede sustituirla por el único criterio del técnico de prevención emitido en

base a las recomendaciones de una guía técnica que carece de carácter vinculante.

B) La primera de las sentencias de esta Sala mencionadas por las recurrentes, de fecha 2.5.2017 (rec 761/2017), dispuso que < < En lo que hace a la medida de los 10 minutos para el aseo personal antes de la comida y de otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo, estando la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 664/1997

(RCL 1997, 1273) como disposición mínima aplicable a las actividades en las que los

trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral, situación en la que se encuentran los afectados por el presente conflicto colectivo (la propia recurrente reconoce que desarrollan la actividad de asistencia sanitaria prevista en el anexo I del RD, sin que cuestione el hecho probado quinto cuando dice que corren el riesgo de contagio por enfermedades infectocontagiosas), sin que en este caso opere la excepción a su aplicabilidad prevista en el art. 4.5 del RD cuando recoge que se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 del RD "salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario", porque, al contrario de lo que entiende la recurrente, la evaluación de riesgos no dice que esa medida sea innecesaria, sino que no tiene sentido la estricta aplicación de 10 minutos para el aseo antes de la comida y al abandonar el trabajo, y sin que tampoco pueda prevalecer la opinión del técnico de prevención que lo haya emitido - por mucho que coincida con lo contemplado en la Guía Técnica elaborada por orden de la DF 1ª del RD 644/1997 , que, no olvidemos, carece de carácter vinculante- sobre una disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados, debemos igualmente rechazar la oposición a la aplicabilidad a los mismos de esta medida . > >

La segunda sentencia de referencia, fechada el 25.9.2018 (rec 1622/2018), señaló, siguiendo la anterior, que < < En el caso que nos ocupa es cierto que en la evaluación específica de riesgos laborales de la residencia demandada de fecha 15 de mayo de 2017 en lo atinente a las medidas del mencionado artículo 7.2, dice: "esta medida sería muy poco eficaz si se realiza tal y como está planteada en el R.D. Sería una medida innecesaria tal y como se plantea en el R.D. por lo que se ha readaptado para que su eficacia sea plena y por lo tanto conseguir una mejora sustancial en la seguridad del personal del centro", "entendemos por tanto que las medidas del artículo 7.2 son estándares de protección y por lo tanto consideramos que las medidas que aplicamos en el Centro mejoran y son más eficaces". / Lo que se viene a decir es que la medida en el plano teórico resulta innecesaria resultando ser mejores las medidas que se aplican en el centro. Pero como dice nuestra sentencia ya citada "no puede prevalecer la opinión del técnico de prevención sobre una disposición mínima aplicable a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados". / Por otra parte dicha medida está indicada en esos casos por la propia Guía Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, si bien no es vinculante. / Y dado que los trabajadores de

*la empresa demandada reúnen los requisitos de exposición a agentes biológicos previstos en el Real Decreto 664/1997 (RCL 1997, 1273) para la aplicación de la medida controvertida, entendemos que la petición de la parte actora resulta atendible, sin que la empresa pueda oponer que ya adopta otras medidas de protección más eficaces que en su caso serían complementarias. >
>*

Y por lo que hace a la última, de fecha 13.11.2018 (rec 2139/18), vino a complementar los argumentos anteriores señalando lo siguiente: < < La empresa demandada reconoce, (y así consta en la evaluación de riesgos laborales), que resulta plausible la exposición de sus trabajadores a agentes biológicos, (aunque su actividad no implica una intención deliberada de manipularlos), por lo que la medida de higiene discutida resulta exigible en la empresa, por remisión del artículo 4.5 del RD 644/1997 .

No cabe entender que la empresa está exenta de esta obligación por previsión expresa de la normativa de prevención de riesgos laborales, como sostiene la recurrente. De la exégesis de la evaluación específica de riesgos laborales de la demandada de fecha 9 de mayo de 2018, que se encuentra reproducida en el hecho probado quinto de la sentencia, se aprecia que dentro de las medidas de higiene se recoge el lavado higiénico de manos, que se realizará de manera continua, no solo al finalizar la jornada o antes e ir a comer. De manera que las medidas de higiene, - en particular el lavado de manos-, antes de ir a comer o antes de finalizar la jornada, sí están contempladas como preceptivas u obligatorias en la propia evaluación de riesgos laborales. Y precisamente la medida reclamada en esta litis va dirigida a dar cumplimiento a las medidas de higiene antes de ir a comer o antes de finalizar la jornada, en la línea que exige la propia evaluación de riesgos laborales. La expresión de que la medida establecida en el apartado segundo del artículo 7 del RD 644/1997 no resulta necesaria en el centro de trabajo, se contradice con las anteriores manifestaciones que la propia evaluación de riesgos contiene, de manera que no puede aceptarse como una exclusión automática de la medida, como pretende la empresa recurrente. /

De hecho, cuando la evaluación de riesgos describe las "medidas de barrera", afirma que se establecerán medidas de lavado higiénico de manos. Por consiguiente, no resulta suficiente con el empleo de guantes, sino que, además, se exige a la empresa implementar medidas de lavado de las manos, que deben llevarse a cabo, como hemos visto, antes de comer o de finalizar la jornada, - sin perjuicio de que también se haga de forma continua durante la misma-. En resumen, la evaluación de riesgos de la empresa, examinada en su conjunto, no excluye la medida del artículo 7.2 del RD 644/1997 , sino que la ampara, pues tiende precisamente a hacer efectivas las medidas de higiene y lavado de manos antes de ir a comer o de finalizar la jornada que son específicamente mencionadas en la propia evaluación. Insistimos en que las otras medidas que menciona la evaluación de riesgos no hacen innecesario el lavado de las manos precisamente antes de comer o de finalizar la jornada, sino que los complementan. / Por otro lado, y como ya dijimos en nuestra

sentencia de dos de mayo de 2017, esta conclusión no puede soslayarse a partir de la guía técnica, que carece de valor vinculante, ni de los informes de la ITSS o de Osalan. / Por último, queremos añadir a nuestros razonamientos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995, 3053) 31/1995, de 8 de noviembre EDL 1995/16211, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 EDL 1995/16211, señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 EDL 1995/16211 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de éstos tres preceptos se deduce, en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 EDJ 2001/49262, "como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. / (¿) Siendo así, debemos afirmar que la medida que el sindicato demandante está reclamando a la empresa demandada tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, y al no tratarse de una medida irracional ni absurda o desproporcionada, debe ser exigible a la demandada por imperativo de la amplia obligación que en esta materia le atribuye la Ley 31/1995 (RCL 1995, 3053) de Prevención de Riesgos Laborales. Si la propia Evaluación de riesgos laborales contempla como preceptivo el lavado de las manos, resulta totalmente justificado y ponderado que el trabajador cuente con un breve período de 10 minutos para hacer efectiva esta medida de seguridad y salud antes comer o de abandonar su puesto de trabajo. /

La medida que examinamos debe ser implementada por la empresa, precisamente para hacer efectivo y para posibilitar el lavado de las manos al personal, y evitar así cualquier distracción u omisión al respecto por las prisas inherentes a las jornadas de trabajo, artículo 15.4LPRL -. Y ello porque, como hemos dicho, las obligaciones en materia de seguridad y salud para la empresa no se constriñen a las reglamentariamente establecidas, sino que deben adoptarse las que sean necesarias, con el único límite de su futilidad, irracionalidad o desmesura. Recordemos en este punto, como colofón a nuestros argumentos, que el trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene, a tenor de lo previsto en el artículo 19 ET (RCL 2015, 1654); y que los propios representantes legales de los trabajadores pueden requerir al empresario para que adopte las medidas oportunas en materia de seguridad, y si la petición no fuese atendida dirigirse entonces a la autoridad competente, - apartado quinto del artículo 19 ET (RCL 2015, 1654) -. Esto es precisamente lo que el sindicato demandante está planteando a través del presente conflicto colectivo, solicitando que por parte de la empresa demandada se implemente la medida que señala el artículo 7.2 del Decreto 644/1997 -. Consideramos que la medida es totalmente razonable, atendiendo al riesgo de contacto con agentes biológicos

que tienen estos trabajadores, y que no resulta superflua, sino que se complementa con otras medidas de seguridad, como los guantes o las mascarillas, que también menciona la evaluación de riesgos laborales . > >

C) Pues bien, volviendo al presente supuesto, como ya dijimos en la primera de las anteriores sentencias (que es firme), la medida contemplada en el art. 7.2 del RD 664/1997 está prevista como disposición mínima aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral (art. 1.2), y en este caso, tal como recoge el hecho probado cuarto de la sentencia recurrida, que no se ha cuestionado, "los trabajadores afectados: personal gerocultor, personal sanitario y personal de limpieza, tienen riesgo por exposición a riesgos biológicos por contacto con fluidos corporales, piel y mucosas en la atención de los residentes".

Disponiendo el art. 4.5 que se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 del Real Decreto salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario, tal innecesariedad no puede derivarse del hecho de que se haya evaluado el riesgo de exposición a los agentes biológicos con severidad leve, probabilidad posible y clasificación bajo, porque quedando patente su concurrencia -además de en el ordinal fáctico cuarto antes aludido- de la propia circunstancia de que en la evaluación de riesgos se fomenta la medida de lavado de manos de forma continuada, esta medida de fomento, de conformidad con las razones ya expuestas en los anteriores pronunciamientos, no altera ni transforma la necesidad de dar a los trabajadores sometidos al riesgo la cobertura de protección prevista en el art. 7.2 del RD 664/1997 ."

Anexo 5: Se adjunta infografía de los 5 momentos de higiene de manos⁴³.



⁴³ Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. (s.f.). Recuperado el 28 de octubre de 2021, de <https://www.sempsph.com/es/noticias/higiene.html?start=40>

Anexo 6 Impugnación del recurso. Jurisprudencia Ilustrativa.

Entre ellas se encuentran la Sentencia Nº 207/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 (autos nº 161/2021) en fecha 4 de junio de 2021 ELA – EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA contra Asociación Urgatzi para la promoción del Bienestar y Comité de empresa de la Residencia San José Etxe Alai; la Sentencia nº 592/2021 de fecha de 23 de marzo de 2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao en fecha 17 de julio de 2020 (Residencia Aita Menni); la Sentencia de Osakidetza: Sentencia nº 1649/2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 15 de diciembre de 2020. La sala desestima íntegramente la demanda de conflicto colectivo promovida por ELA, SATSE, LAB, CCOO, UGT y ESK frente a Osakidetza y, por último, la Sentencia nº 1092/2019 de fecha de 4 de junio de 2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Residencia "Santa Casa de Misericordia").

Sentencia nº 350/2021 dictada el 21 de julio de 2021, por el Juzgado de lo Social nº 6 (autos 639/2021), seguidos a instancia de la Confederación Sindical ELA STV contra Ute Urbi Hiru Muskiz Residencia Marcelo Gangoiti, Babesten S.L, Aztertzen Servicios Asistenciales S.L y Comité de Empresa.

En dicha sentencia se establece lo siguiente en su Fundamento de Derecho Segundo: SEGUNDO.- SOLUCIÓN AL CASO “La más reciente sentencia de la Sala propósito de la cuestión se concreta en la de 23-3-2021, RAJ 170.277, que habría confirmado una precedente del JS nº 3 de esta plaza. En la misma se incluye este extracto: “Ha quedado acreditado mediante la evaluación de riesgos laborales practicada y vigente en la empresa (que no ha quedado desvirtuado en los recursos) que en el ámbito laboral de la demandada la exposición a agentes biológicos es accidental. A ello se une la previsión de la evaluación de riesgos sobre la pormenorizada enumeración de todos los actos que a lo largo de la jornada requieren la inmediata limpieza del trabajador.

La escasa exposición a los agentes biológicos y el protocolo de higiene que resulta más estricto y protector que la exigencia legal, implica que el derecho reclamado, previsto por el [art. 7](#) del Real Decreto 664/1997 cuente con la excepción del art. 4.5 de la misma norma.”

En definitiva, la Sala habría acogido un nuevo criterio por el que considera que el establecimiento de una serie de directrices avalada por el plan de prevención de riesgos -enderezadas a garantizar el mismo propósito que pretende el precepto sobre el que los demandantes sostienen su pretensión- haría ocioso imponer lo previsto en aquella norma, al satisfacerse en mejores condiciones el mismo objetivo pretendido por el artículo 7.2 RD 664/1997.

A este particular, el eventual contacto de los trabajadores con muestras susceptibles de generar riesgo biológico viene a atajarse por el protocolo genérico a que hemos hecho alusión en el ordinal 3º del relato, que contempla

la necesidad de proceder con el lavado de manos en cinco situaciones concretas, a lo que se añade la relevante prevención de impedir que los trabajadores lleven a casa sus ropas de trabajo. Por tanto, en el caso que nos ocupa, nos volvemos a encontrar con disposiciones suficientes dentro del manual de prevención de riesgos, factor este que propicia la extensión de la doctrina contenida en el indicado pronunciamiento al que ahora nos ocupa.

Asimismo, no cabe considerar que los 10 minutos a los que se refiere el citado precepto tengan como objeto un aseo genérico (no necesariamente orientado a contener el riesgo) tras la realización de las tareas ordinarias, toda vez que la norma en la que estaría incluida esa previsión está relacionada con la materia preventiva, por lo que no puede limitarse al reconocimiento de un derecho genérico. Abunda sobre esta línea de razonamiento el hecho de que el propio precepto quede excepcionado cuando la estrategia de prevención de riesgos adoptada lo haga innecesario, factor este que avala la necesidad de conectar el aseo a que se refiere el artículo 7.2 RD 664/1997 con la contención de un eventual peligro.”

Sentencia de Osakidetza: Sentencia nº 1649/2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 15 de diciembre de 2020. La sala desestima íntegramente la demanda de conflicto colectivo promovida por ELA, SATSE, LAB, CCOO, UGT y ESK frente a Osakidetza.

“La obligación y el derecho del personal sanitario a observar los protocolos de higiene que se materializan en numerosos actos de aseo a lo largo de su jornada laboral, conforme establecen las guías para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, constituye algo consustancial e intrínseco a su trabajo; y por ello están perfectamente instruidos de cómo, cuándo y por qué han de practicar cada acto de aseo, de tal manera que el aseo previo a la comida o el aseo al finalizar la jornada no es distinto a todos los aseos que a lo largo de la misma han de realizar, de tal manera que no se pueden separar unos de otro para reconocer como derecho distinto o especial el aseo previo a la comida o al finalizar la jornada respecto a todas las ocasiones en que el mismo aseo ha de realizarse.

Los 10 minutos que reconoce el tantas veces citado art. 7.2 del Real Decreto 664/1997 sólo encuentra fundamento cuando no es procedente, conveniente, posible o práctico hacer aseos intermitentes a lo largo de la jornada, lo que conduce a la necesidad de una única limpieza profunda que requiere 10 minutos de dedicación.”

Lo que no es lógico no es jurídico. Decimos esto porque la tesis que defiende la parte actora conduciría al absurdo de que cada vez que el personal sanitario toca algo o a alguien que de seguido requiera el oportuno aseo, a éste habría que dedicarle siempre 10 minutos, lo que implica, sin exageración ni riesgo de equivocarse, que el tiempo dedicado al aseo a lo largo de la jornada sumaría varias horas. Por coherencia con lo reclamado en la demanda, la estimación de ésta conformaría tal situación que clamorosamente resulta jurídicamente insostenible.”

Sentencia nº 592/2021 de fecha de 23 de marzo de 2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se confirma íntegramente la sentencia desestimatoria dictada por el juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao en fecha 17 de julio de 2020 (Residencia Aita Menni).

“FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO Pág.5 de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N°3

“Por lo tanto los protocolos existentes aseguran ese lavado de manos antes de comer y al final al finalizar la jornada laboral y en muchas ocasiones no previstas en las normas mínimas del Real decreto 664/1997 por lo que la empresa ha quedado integrada en la excepción prevista en el artículo 4.5 del Real decreto citado.

“Si el personal de la empresa procede de forma rigorista al cumplimiento de los protocolos de actuación de aseo de manos existentes en la empresa con descontaminación y lavado en cada 1 de los supuestos contemplados por el tiempo necesario, la aplicación formalista de 10 minutos al finalizar la jornada carece de justificación más teniendo en cuenta el riesgo bajo de la exposición por la exposición potencial agentes biológicos.”

La Sala recoge literalmente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Bilbao que:

“Los protocolos existentes aseguran ese lavado de manos antes de comer y al finalizar la jornada laboral, y en muchas ocasiones no previstas en las normas mínimas del RD 664/1997, por lo que la empresa queda integrada en la excepción del artículo 4.5 del RD citado.

Si el personal de la empresa procede de forma rigorista al cumplimiento de los protocolos de actuación de aseo de manos existe en la empresa, con descontaminación y lavado en cada uno de los supuestos contemplados por el tiempo necesario, la aplicación formalista de 10 minutos al finalizar la jornada carece de justificación, más teniendo en cuenta el riesgo bajo de la exposición por exposición potencial a agentes biológicos”.

Sentencia N° 207/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 (autos nº 161/2021) en fecha 4 de junio de 2021 ELA –EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA contra Asociación Urgatzi para la promoción del Bienestar y Comité de empresa de la Residencia San José Etxe Alai.

FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO:

En virtud de lo expuesto, IMQ Prevención concluye para todos los puestos de interés actual, que resulta innecesaria la medida establecida en el apartado 2º del artículo 7 RD 664/97 "a la vista del resto de medidas higiénicas y de protección adoptadas en cada uno de los puestos de trabajo en los que se ha

evaluado el riesgo biológico". (...) En definitiva, y adoptando como referente de autoridad la STSJ PV 23/03/21 recurso 247/21 oportunamente invocada por la empresa y dictada en un supuesto asimilable en lo sustancial al presente, lo actuado revela la escasa exposición efectiva a agentes biológicos en los puestos de trabajo y la existencia de formación, así como de un protocolo de higiene más garantista y protector que el previsto en el artículo 7.2 RD 664/97, con lo que resulta de aplicación la excepción prevista en el artículo 4.5 del mismo RD, desestimándose la demanda".

Bibliografía

- *Unión de mutuas (Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 267)*. (s.f.). Recuperado el 28 de octubre de 2021, de <https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/03/Cartel-EPIS.pdf>

- *Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.* (s.f.). Recuperado el 28 de octubre de 2021, de <https://www.sempsph.com/es/noticias/higiene.html?start=40>